G901:A-0005150951

2003학년도

취업규칙 변경에 따른 문제점에 관한 연구

A Study about Points,
according to change on Rules of Employment

圓 光 大 學 校 大 學 院

法 學 科

黃 炫 淳

취업규칙 변경에 따른 문제점에 관한 연구

A Study about Points,
according to change on Rules of Employment

指導敎授　李 羲 成

이 論文을 法學碩士學位論文으로 提出함.

2003년　10월

圓 光 大 學 校　大 學 院

法　學　科

黃　炫　淳

黃 炫 淳의 法學 碩士學位論文을 認准함.

審 査 委 員

審 査 委 員 長 洪 起 甲 印

審 査 委 員 金 大 圭 印

審 査 委 員 李 義 成 印

圓 光 大 學 校 大 學 院

2003년 12월

目　　次

국문초록 및 ABSTRACT

제1장 서　론 ····· 1

제1절 연구의 목적 ····· 1
제2절 연구의 범위와 방법 ····· 4

제2장 취업규칙의 의의와 법적 성질 ····· 6

제1절 취업규칙의 의의 ····· 6
제2절 취업규칙의 법적 성질 ····· 7
1. 학 설 ····· 8
1) 계약설 ····· 8
2) 법규범설 ····· 11
3) 그 밖의 논의 ····· 14
2. 판례의 입장 ····· 16
3. 소 결 ····· 17

제3장 취업규칙 변경에 관한 문제점 ····· 19

제1절 개 관 ····· 19
1. 문제의 소재 ····· 19
2. 취업규칙의 일반적 변경의 의의 ····· 20
3. 취업규칙의 불이익 변경의 의의 ····· 20
제2절 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론 ····· 21
1. 근기법 제97조 제1항의 단서 ····· 21

1) 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의 ····· 23
2) 동의의 방식 ····· 24
2. '합리성'이론 ····· 26
1) '합리성'이론의 도입 ····· 27
2) '합리성'이론에서의 사회적 상당성의 원칙 ····· 28
제3절 취업규칙 변경의 효력상의 문제점 ····· 29
1. 집단적 동의를 얻은 경우 ····· 30
1) 단체협약에 의한 동의의 경우 ····· 30
2) 비조합원에 대한 불이익 변경된 취업규칙의 적용여부 ····· 32
3) 불이익 변경의 소급효 문제 ····· 35
2. 집단적 동의를 얻지 못한 경우 ····· 38
1) 개별적 동의가 있는 경우 ····· 38
2) 취업규칙 변경 후 신규입사자에 대한 적용의 문제 ····· 39
3) 변경 후 유리하게 된 경우 ····· 42
제4절 취업규칙의 불이익변경의 구체적 판단기준 ····· 44
1. 임금에 관한 구체적 판단 ····· 44
1) 불이익 판단기준 ····· 44
2) 연봉제 도입의 경우 ····· 47
2. 퇴직금에 관한 구체적 판단 ····· 48
1) 단체협약에 의한 불이익변경의 동의 ····· 48
2) 불이익 판단기준 ····· 50
3. 근로시간에 관한 구체적 판단 ····· 51
1) 불이익판단의 기준 ····· 51
2) 탄력적 근로시간제의 도입의 경우 ····· 52
4. 정년제에 대한 구체적 판단 ····· 54
1) 정년제의 신설의 경우 ····· 54
2) 정년의 단축의 경우 ····· 56
제5절 기업변동시 취업규칙의 변경에 관한 문제점 ····· 57
1. 문제제기 ····· 57
2. 근로관계의 승계여부 ····· 58

3. 기업변동시 취업규칙의 효력 ····· 61
1) 법규범설의 입장에서의 효력 ····· 61
2) 계약설의 입장에서의 효력 ····· 62
3) 소 결 ····· 63
4. 기업의 변동으로 인한 취업규칙의 변경의 구체적 사례 ····· 64
1) 하나은행 ····· 64
2) 국민은행 ····· 66

제4장 취업규칙의 변경에 따른 문제점의 개선방향 ····· 68

제1절 '합리성'이론의 배제 ····· 68
1. 일본에서의 '합리성'이론의 필요성 ····· 68
2. 우리 나라에서의 '합리성'이론의 배제 ····· 69
제2절 불이익 변경시 효력상의 문제점의 개선방향 ····· 70
1. 취업규칙과 단체협약의 관계의 정립 ····· 70
2. 유리한 원칙의 타당범위에 대한 고찰 ····· 73

제5장 결 론 ····· 77

참고문헌 ····· 80

국 문 초 록

현행 근로기준법 근로조건에 관하여 사용자와 근로자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정되어야 한다라고 하면서도, 한편 사용자에게는 포괄적인 내용을 규정할 수 있도록 취업규칙의 작성권한을 부여하고 있다.

그런데 대량적·획일적으로 거래되는 노동시장에서 이러한 취업규칙에 대하여 근로자가 거부의 뜻을 표현한다는 것은 사실상 고용기회의 상실을 의미하는 것이다. 따라서 근로자가 근로계약의 체결을 거부하지 않는 이상 이는 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 근로계약의 내용으로 받아들인다는 의미로 해석되는 것이다.

다만 이에 대하여 근로기준법은 근로자 보호의 차원에서 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 강제하고 있는바 취업규칙을 게시하여 근로자에게 주지시킬 것, 취업규칙의 불이익변경에는 일정한 절차를 거치도록 할 것, 감급에 대한 제한 및 제재규정의 제한, 단체협약에 반할 수 없도록 한 것, 그리고 이를 위반한 경우에 사용자에게 제재를 가하도록 하고 있다.

그러나 취업규칙의 작성·변경권이 원칙적으로 사용자에게 있고 근로관계의 현실에서 일종의 규범으로 작용하여 근로자를 구속한다는 사실자체에는 변함이 없다. 또한 취업규칙의 불완전성으로 말미암아 노·사간의 법적 분쟁을 초래하고 노동쟁의까지 이르는 사회문제로 야기되고 있는 실정이다.

특히 이와 같은 취업규칙의 문제점은 취업규칙의 불이익변경시에 나타나는바 취업규칙의 변경의 문제점과 관련하여 논의의 대상이 되어온 것은 첫째 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론과의 충돌문제와 둘째 사용자에 의하여 일방적으로 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력 여부에 관한 것, 취업규칙의 변경에 있어서 불이익판단기준에 대한 것과 셋째 기업변동시 취업규칙의 변경에 관한 문제점 등이 있다.

따라서 본 연구는 제1장에서 연구의 목적과 범위·방법을 제시하기로 한다. 제2장에서는 취업규칙에 관한 일반론(의의 및 법적 성질의 고찰)적인 고찰을 통하여 취업규칙에 대한 의의를 정립하고 계약설과 법규범설로 대별되는 취업규칙의 법적 성질을 확정한 다음에 그에 따른 통일적인 서술을 시도하고자 한다.

제3장에서는 취업규칙의 변경에 관한 문제점을 고찰하기로 한다. 취업규칙의 변경과 관련하여 여타의 문제점들이 제기 될 수 있겠는바 본 장에서는 취업규칙의 변경의 의의와 불이익 변경의 의의를 살펴본 다음 특히 문제점으로 인식되어온 취업규칙의 불이익 변경에 관한 문제점을 중심으로 검토하기로 한다. 취업규칙의 불이익 변경에 관한 문제점 중에서 특히 근로기준법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론과의 충돌문제·취업규칙의 불이익 변경의 효력상의 문제·취업규칙의 불이익 변경의 판단기준상의 문제·기업변동시에 나타나는 취업규칙의 승계 및 효력에 관한 문제점을 본 장에서 다루고자 한다.

제4장에서는 미력하나마 취업규칙의 변경에 관한 문제점의 개선방향을 제시해보고자 한다. 이에 외국의 입법례 및 학설 등을 살펴봄으로서 우리의 현실에 맞는 취업규칙 변경과 관련된 문제점들을 개선할 수 있는 합리적인 방법을 모색하고자 한다.

제5장에서는 본 연구를 정리하면서 부족하나마 현행 취업규칙에 대한 통일적이고도 체계적인 법리해석방안과 불완전한 취업규칙법제의 입법적 해결책을 제시하며 본 연구를 마무리하기로 한다.

ABSTRACT

A Study about Points, according to change on Rules of Employment

Hwang, Hyeon-Soon
Department of Law
Graduate School of
Wonkwang University

In operation the Labor Standard Act about working condition, It is prescribed in the rules of law, to equal rights An employer and a laborer be decided by free will. However a law grant a making power of rules of employment right to employer.

Yet to labor market be do business with a large quantity and uniform, the above statements about rules of employment, doing labor express an intention of disapproval mean loss of employment chance.

According to labor do not disapprove of conclude contract employment a contract because my employment. only about this way the Labor Standard Act be force rules of employment to labor protection. here there are some way.

Watching for, inform notify to labor doing placard rules of employment, doing go through formalities in disadvantage change of rules of employment, limitation of lower labor salary and punishment rule, doing non-objection a collective agreement etc.

But on actuality of labor relation, operating rules of employment a kind of rule, show no change a fact on put under restraint, in principle framing and change rights of rules of employment have

employer. Also these are caused social problem bring about employer and a laborer legal struggle be due to an imperfection of rules of employment.

Especially having been became the subject of discussion be related to problem on rules of employment, it come to the front disadvantage changing time rules of employment.

The first, a collision problem of a proviso Clause .1 of Article. 97 of the Labor Standard Act and a theory of 'rationality', the second about thing of effect disadvantage changing rules of employment, one-sided be owing to employer. The third about thing, a standard of judgment of disadvantage on changing rules of employment. finally there was problem about changing rules of employment, on change time of enterprise.

Accordingly, this study exhibit scope, method and object of study to the first chapter. To the second chapter, will be attempts to description about a theory of general of rules of employment-becoming division a theory of contract and norm, then regal quality settled.

To the third, it has consider points about change rules of employment. concerning it, may be become some problem proposal, to the chapter, giving a problem change rules of employment careful consideration.

To the forth, it may have presented shortage improvement direction of it. then looking around a theory and example of legislation of foreign, it may have groped rational a method.

Finally arranging a study, presenting a solution of legislation imper -fection rules of employment, a study may have completed.

제1장 서 론

제1절 연구의 목적

오늘날 인간이 자급자족의 경제생활을 고수하지 않는 한 노동인격에 의한 직업에 종사지 않을 수 없다. 즉 대다수의 인간들은 그들의 생계를 확보하기 위하여 사용자에 종속하여 일하는 근로자의 길을 택하여야 할 것이다. 이러한 근로자가 되기 위하여 처음 단계를 거쳐야 하는 것이 '직장의 마그나 카르타'[1] 라고 하는 취업규칙이다. 그리고 취업규칙은 오늘날 하나의 노동법 제도로서 존재하고 있고, 근로관계의 현실에서는 대부분의 근로계약이 이에 의하여 이루어지고 있다. 즉 개개 근로자와 사용자 사이에 개별적이고 구체적인 합의에 의하여 근로계약이 체결되는 것보다 취업규칙이라는 일종의 보통거래약관[2]에 의하여 이루어지고 있는 것이다. 물론 복무규율이나 근로조건에 관하여 근로계약, 단체협약 등을 통해 사용자와 근로자 또는 근로자집단이 자주적으로 형성하는 외에 근로기준법이 강행적으로 규정하고 있다. 그러나 그 형성방식에 있어서 근로계약은 사용자와 개별근로자, 단체협약은 사용자 또는 사용자단체와 노동조합간의 자주적 계약체결이나 교섭에 의하고 근로기준법은 국가가 노·사 관계에 직접적으로 개입하기 위하여 설정한 법규범인데 반하여 취업규칙은 사용자와 한 사업장 내의 전체근로자와의 관계인 점, 반드시 노동조합과의 교섭을 전제로 하고 있지 아니한 점, 국가가 설정한 것이 아니라 사인이 설정한 규범임에도 법규범화 하고 있는 점에서 차이가 있다.

---

1) 이 성삼, 취업규칙에 관한 연구, 중앙대 석사학위논문, 1989, 1면.
2) 보통거래약관과의 비교에 대해서는 이은영, 취업규칙의 불이익변경, 김치선박사화갑기념, 노동법의 제문제, 박영사, 1983, 221-222면.

현행 근로기준법(이하 “근기법” 이라 약칭한다)은 근로조건에 관하여 사용자와 근로자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정되어야 한다(근기법 제3조)라고 하면서도, 한편 사용자에게는 포괄적인 내용을 규정할 수 있도록 취업규칙의 작성권한을 부여하고 있다.

그런데 대량적・획일적으로 거래되는 노동시장에서 이러한 취업규칙에 대하여 근로자가 거부의 뜻을 표현한다는 것은 사실상 고용기회의 상실을 의미하는 것이다. 따라서 근로자가 근로계약의 체결을 거부하지 않는 이상 이는 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 근로계약의 내용으로 받아들인다는 의미로 해석되는 것이다.

다만 이에 대하여 근기법은 근로자 보호의 차원에서 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 강제하고 있는바 취업규칙을 게시하여 근로자에게 주지시킬 것(근기법 제13조), 취업규칙의 불이익변경에는 일정한 절차를 거치도록 할 것(근기법 제97조), 감급에 대한 제한 및 제재규정의 제한(근기법 제98조), 단체협약에 반할 수 없도록 한 것(근기법 제99조), 그리고 이를 위반한 경우에 사용자에게 제재(근기법 제115조)를 가하도록 하고 있다.

그러나 취업규칙의 작성・변경권이 원칙적으로 사용자에게 있고 근로관계의 현실에서 일종의 규범으로 작용하여 근로자를 구속한다는 사실자체에는 변함이 없다. 또한 취업규칙의 불완전성으로 말미암아 노・사간의 법적 분쟁을 초래하고 노동쟁의까지 이르는 사회문제로 야기되고 있는 실정이다. 그렇다면 국가가 제정한 법규도 아니고 계약당사자간의 합의도 아닌 사용자가 일방적으로 작성한 계약초안에 불과한 취업규칙이 어떠한 근거로 근로자를 법적으로 구속할 수 있는지가 의문이다.

이것이 바로 취업규칙의 법적 성질의 문제이며, 이러한 취업규칙이 변경된 경우에 나타나는 문제점들과 관련하여 중요한 의미를 가지는 것이다. 특히 취업규칙의 변경은 1997년의 IMF경제위기를 기점으로 하여 사용자들이 경영사정의 악화를 이유로 취업규칙을 근로자들에게 불이익하게 변경하기 시작하였다. 그리고 사용자의 취업규칙 불이익변경은 현재에 이르러 정리해고 또는 부

당노동행위의 대체수단으로 활용하는 경향까지 보여주고 있다.

상술한 바와 같은 내용을 바탕으로 본 연구는 취업규칙의 법적 성질을 명확히 한 다음에 이를 토대로 하여 취업규칙의 변경에 대한 문제점들을 살펴보고 취업규칙의 변경과 관련한 판례와 제 이론들을 통하여 근로자보호의 이념으로부터 무엇이 가장 타당한 법리해석인가를 밝히는데 노력하고자 한다. 그리고 이를 통하여 현행의 취업규칙에 관련한 법제를 보완할 수 있는 방향을 제시하고자 한다.

제2절 연구의 범위와 방법

취업규칙의 변경의 문제점과 관련하여 논의의 대상이 되어온 것은 첫째 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론과의 충돌문제와 둘째 사용자에 의하여 일방적으로 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력 여부에 관한 것, 취업규칙의 변경에 있어서 불이익판단기준에 대한 것과 셋째 기업변동시 취업규칙의 변경에 관한 문제점 등이 있다. 이는 취업규칙의 법적 성질과 관련하여 일관되게 논하지 않으면 안될 것이다.

따라서 본 연구에서는 상술한 바와 같이 제1장에서 연구의 목적과 범위·방법을 제시하기로 한다.

제2장에서는 취업규칙에 관한 일반론(의의 및 법적 성질의 고찰)적인 고찰을 통하여 취업규칙에 대한 의의를 정립하고 계약설과 법규범설로 대별되는 취업규칙의 법적 성질을 확정한 다음에 그에 따른 통일적인 서술을 시도하고자 한다.

제3장에서는 취업규칙의 변경에 관한 문제점을 고찰하기로 한다. 취업규칙의 변경과 관련하여 여타의 문제점들이 제기 될 수 있겠는바 본 장에서는 취업규칙의 변경의 의의와 불이익 변경의 의의를 살펴본 다음 특히 문제점으로 인식되어온 취업규칙의 불이익 변경에 관한 문제점을 중심으로 검토하기로 한다. 취업규칙의 불이익 변경에 관한 문제점 중에서 특히 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론과의 충돌문제·취업규칙의 불이익 변경의 효력상의 문제·취업규칙의 불이익 변경의 판단기준상의 문제·기업변동시에 나타나는 취업규칙의 승계 및 효력에 관한 문제점을 본 장에서 다루고자 한다.

제4장에서는 미력하나마 취업규칙의 변경에 관한 문제점의 개선방향을 제시해보고자 한다. 이에 외국의 입법례 및 학설 등을 살펴봄으로서 우리의 현실에 맞는 취업규칙 변경과 관련된 문제점들을 개선할 수 있는 합리적인 방법을 모색하고자 한다.

제5장에서는 본 연구를 정리하면서 부족하나마 현행 취업규칙에 대한 통일적이고도 체계적인 법리해석방안과 불완전한 취업규칙법제를 보완할 수 있는 방향을 제시하며 본 연구를 마무리하기로 한다.

제2장 취업규칙의 의의와 법적 성질

제1절 취업규칙의 의의

근로계약은 사용자가 근로자와 개별적으로 체결하고 내용을 확정하는 것이 원칙이지만, 근로관계는 어느 정도 정형화되어 있기 때문에 근로계약의 체결에 있어서 취업규칙을 이용하는 것이 일반적 현상이다. 취업규칙이란 사용자가 다수의 개별적 근로관계의 처리상의 편의를 위하여 근로계약의 내용이 되는 사항과 복무규정 및 직장질서에 관한 사항을 일방적으로 정한다는 점에서 보통계약약관과 법률상의 본질은 다를 바가 없다. 이에 일반적으로 취업규칙은 사용자가 일방적으로 작성하는 것으로서 사업장에서 근로자가 취업상 준수하여야 할 규율과 임금, 근로시간 등의 근로조건에 관한 구체적인 사항을 정한 규칙류를 총칭하는 것이라고 볼 수 있다.[3)4)5)]

근기법은 근로자가 사실상의 경제적·사회적 종속성으로 인하여 취업규칙의 일반적 적용에 반대하기 어려운 사정을 고려하여 취업규칙의 작성시에 일련의 내용을 신고규정을 두고 있다. 즉, 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 소정의 취업규칙을 작성하여 노동부장관에게 신고하도록 하고, 노동부장관은 법령이나 단체협약에 저촉되는 취업규칙에 대하여는 변경을 명할 수 있

---

3) 이에 대하여 취업규칙을 광의와 협의의 두 개의 범주로 나누어서 광의로 쓰이는 경우에는 기업의 경영을 원활하게 운영하기 위해 기업의 있어서 규율을 정하고, 또는 거기에 취업하는 근로자의 근로조건 등을 정하는 규정전체라고 이해하는 견해도 있다. 이에 따르면 노동조합과 사용자와의 사이에서 체결된 단체협약 중 이러한 종류의 규정도 취업규칙이 될 수 있으나 근기법 제96조 이하가 규제의 대상으로 하는 것은 협의의 취업규칙, 즉 사용자가 당해 사업장의 근로자에게 적용하기 위하여 일방적으로 작성한 공동작업상의 질서를 말하는 것이다: 김 영, 취업규칙의 법리와 문제점, [노사관계] 제1권 제2호, 한국노사발전연구원, 1990, 87-88면.

4) 대판 93다27413, 93다30181, 95누15698.

5) 임 종률, 노동법, 박영사, 2002, 315면; 김 형배, 노동법, 박영사, 2002, 206-207면.

도록 하였으며, 취업규칙의 작성시에는 근로자들의 의견을 듣도록 하고 있다.

그리고 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 동의를 얻도록 함으로써 내용상의 적정을 기하도록 하고 있다. 또한 취업규칙은 법령이나 당해 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없다는 점을 규정하고 있다. 특히 근로자의 보호를 위하여 취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 하도록 하고, 그 무효부분은 취업규칙에 정한 기준에 의하도록 취업규칙의 보충적 효력에 대해 규정하고 있다.(근기법 제100조)

제2절 취업규칙의 법적 성질

현행 근기법은 취업규칙을 사용자의 일방적 의사로 작성·변경할 수 있음을 인정하는 동시에 취업규칙을 불이익하게 변경하는 경우에는 일정한 절차[6]를 거치도록 하고 있다. 또한 취업규칙에 대하여 법령이나 단체협약에 우선하는 효력을 인정하지는 않지만, 당사자 쌍방의 합의로 성립한 근로계약(취업규칙이나 단체협약에 반하는 근로계약)을 깨뜨리는 효력을 인정하고 있다.[7] 이와 같이 국가가 제정한 법규도 아니고 당사자간 합의한 계약도 아닌 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙이 어떻게 근로자와 사용자를 구속하는 것인가? 이것이 바로 취업규칙의 법적 성질에 관한 문제이다.

이것은 단지 이론적인 문제가 아니라 사용자에 의한 취업규칙의 불이익 변경시에 그리고 기업변동시에 나타나는 취업규칙의 승계 및 변경에 있어서 그 근거로 작용하기 때문에 매우 중요하다고 볼 수 있다.

---

6) 근기법 제97조-99조 참조.

7) 근기법 제100조 이하에서 취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 대하여 무효로 하고, 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 의한다라고 하고 있다.

취업규칙의 법적 성질에 관하여는 학설이 일치되어 있지 않아 통설이라고 할 수 있는 견해를 확정하기 어려운 형편이다. 이와 같이 견해가 나누어지는 이유로는 대체로 다음과 같은 세 가지 점[8]이 지적되고 있다.

첫째 근로조건의 결정에 관하여 노동법은 노·사 대등의 원칙을 이상으로 하고 있으면서(근기법 제3조), 취업규칙에 관해서는 사용자의 일방적 제정 또는 변경을 부인하지 않고 있다.(근기법 제96조, 제97조)

둘째 근대법은 국가제정법과 계약 이외에는 당사자를 구속하는 법규범을 인정하고 있지 않으나, 취업규칙은 사회규범으로서 사실상 당사자를 구속하고 있다. 그러나 단순히 그러한 이유만으로 취업규칙을 법규범으로 인정할 수는 없으므로 취업규칙의 규범성에 관하여는 법 이론상 여러 가지 논의가 행하여지게 되는 것이다.

셋째 취업규칙은 최종적으로 사용자가 결정하도록 되어 있음에도 불구하고 취업규칙이 노동보호적 역할을 할 수 있다는 점이다.

1. 학 설

1) 계약설

계약설은 근대법 원리와 시민법의 법이념을 관철하여 취업규칙을 일종의 계약으로 보는 것이며 계약설은 계약법원리에 기하여 근로자의 명시 또는 묵시의 합의를 근거로 하여 취업규칙의 법적 구속력을 인정하는 견해이다.

취업규칙은 사용자가 일방적으로 작성·변경할 수 있지만 근로조건은 당사자 일방의 자유로운 합의에 의해 결정되어야 하므로 당사자를 구속하기 위해서는 근로자의 동의가 필요하다는 주장이 계약설이다. 계약설은 취업규칙이 정한 바에 따라 근로관계를 규율하려는 당사자의 의사 즉, 노·사간의 계약에서 법적 구속력의 근거를 구하고자 한다. 또한 계약설은 근로조건의 노·사

8) 김 형배, 전게서, 208면.

대등 결정의 원칙에 충실할 것을 그 목적으로 한다.

그리고 계약설은 취업규칙의 구속력 내지 규범력의 근거가 되는 동의를 둘러싸고 다시 견해가 나뉜다.

우선 순수계약설[9]이라함은 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙은 일종의 정형화된 계약조건에 불구하나 그 내용에 근로자가 동의함으로써 법적 효력을 가지게 된다고 한다. 그리고 이 설은 취업규칙이 근로자에 제시되고 있으면 근로자가 그 내용을 알고 있거나 알지 못할 경우에도 근로계약의 내용이 되지만 전혀 제시되지 않은 경우에는 그것은 계약당사자의 일방적 의사에 불구하며 법적 의미를 갖지 않는다고 할 것이다. 즉, 근로자가 취업규칙의 내용 전부를 알고서 계약한 경우에만 취업규칙이 근로자를 구속한다는 것이다.

당사자합의설[10][11]이라함은 자본주의 노동관계의 속성상 근로자는 근로계약의 내용을 규율하는 취업규칙에 동의할 수밖에 없는 것이므로 근로계약 체결시 취업규칙이 근로자에게 제시되어 있다면, 취업규칙을 근로계약의 내용으로 함에 당사자의 묵시적인 합의가 있다고 추정하는 것이다.

근로자는 사용자와의 사이에 일일이 자기의 근로조건에 관한 개별적 절충토의를 거쳐 근로계약을 체결하거나 아니함에 대한 거취를 결정하는 것이 아니라, 미리 사용자가 일방적으로 정하여 제시한 취업규칙을 일괄하여 수락하고 사용자측에서 정한 바와 같은 임금 그 외에 근로조건에 따라 노동력을 매도한다는 취지를 명시 또는 묵시적으로 합의하는 것이 일반적인 사례이어서, 그 결과 취업규칙에 정한 근로조건은 근로계약의 내용을 이루고 취업규칙이 변경되어진 때는 근로계약의 내용도 따라서 당연히 변경을 받는 것으로 된다.

그러나 이 견해는 사용자가 취업규칙을 제시한 사실만으로 당사자간에 합의

---

9) 이러한 순수계약설을 취하는 견해는 우리 나라는 물론 일본에서도 찾아보기 힘들다: 이 은영, 위의 논문, 221면.
10) 三宅正男, 就業規則, 法律學體系, 法學理論編, 1952, 76면.
11) 昭和電工事件判決(동경고재 54. 8. 31, 노민집 5권 5호, 479면).

가 되었다고 하여, 심지어 근로자가 반대한 경우에도 합의를 의제하는 큰 결함이 있으며 인격의 자유와 계약의 자유라는 시민법원리에 입각한 견해로서 그러한 시민법원리를 수정 내지 부정하는 입장으로부터 출발한 생존권사상, 노동법의 기본원리와는 맞지 않는다는 점에서 비판되어진다.[12]

사실규범설[13]은 사용자가 일방적으로 작성하는 취업규칙을 사실상의 기준, 즉 사실규범으로 보아 취업규칙 그 자체에 법적 구속력을 인정하지 아니하고 근로자의 묵시 또는 명시의 합의가 있을 때에만 법적 효력이 생긴다고 한다.[14] 그러나 이 견해가 출발점으로 삼고 있는 근대시민법원리에 비추어 볼 때 시민법상 개인을 구속하는 것은 계약밖에 없고 그 계약조건이 사회규범화하고 있다 할지라도 그것은 어디까지나 계약내용에 불과하지 그것을 사실규범이라고 할 실익이 없다[15]는 비판이 제기 되고 있다.

사실인 관습설[16]은 취업규칙을 법규범으로 인정할 수 없다는 전제하에 취업규칙은 계약의 청약적 성질을 갖기 때문에 그것이 각개의 근로계약의 내용으로 수용되기 위하여는 어떠한 형태로든 근로자의 동의를 전제로 해야 하지만, 개개 근로자로부터 일일이 구체적 합의를 구하는 것이 어려우므로 근로자는 취업규칙 그 자체에 대하여 반대의 의사표시가 없는 한 취업규칙의 내용이 근로계약의 내용으로 되는 것을 승인한 것이라고 볼 수 있다.

따라서 사용자와 근로자 사이의 단체협약에 의하지 않는 한 취업규칙에 따

---

12) 古西信夫, 就業規則論の展望, 勞働基準法の課題と展望, 青木宗也先生還歷記念論文集, 日本評論社, 1984, 203면.
13) 吾妻光俊, 勞動契約の就業規則, 法律時報 2권 1호, 39면.
14) 日本通運柏崎支店事件決定: 원래 취업규칙은 사업장에 있어서의 질서유지를 위하여 근로자가 취업상 준수할 규율 및 근로조건에 관한 구체적 세목 등을 사용자가 일방적으로 정한 것에 불과하므로 법적규범으로서 사용자를 구속하는 것으로는 해석할 수 없다. 근로자가 본 건과 같이 징계해고의 사유 및 절차 등 근로관계의 중요한 규정에 대하여 법적규범으로서의 효력을 가지도록 희망하는 경우에는 노사간의 단체교섭에 따라 체결된 단체협약에 따를 수 있을 것이다; 新潟地裁 54. 8. 31, 노민집 2권 4호, 403면.
15) 박상필, 전개판 한국노동법, 대왕사, 1991, 337면.
16) 김 형배, 전게서, 210면.

른다는 것이 그 기업 내에 있어서 사실인 관습으로서 통용되고 있다는 것이다.[17] 즉 근로자가 개별적으로 혹은 노동조합을 통해서 특히 이의를 표명하지 않는 한, 개개의 구체적인 노사관계에 관한 것이 아니라 일반적인 노사관계에 있어서 근로계약이 '취업규칙에 의한다'라는 사실인 관행이 존재하게 된다는 것이며 이것을 통하여 취업규칙이 법적으로 개개 근로계약의 내용이 된다는 것이다.[18]

그러나 이 설에 대하여 사실인 관습의 인정을 위한 기준이 제시되어 있지 않다는 것도 지적될 수 있겠다. 즉 '사용자들의 취업규칙에 의한다'는 관습은 노동자들의 관습으로 의제 될 수 있는가? 또는 사실인 관습의 인정을 위해서는 어떤 범위의 구체적인 관행을 요구하는가? 등의 까다로운 문제점이 있다는 비판이 제기 되고 있다.[19]

2) 법규범설

취업규칙의 법적 성격을 법규범으로 보는 법규범설은 근로자가 근로계약을 체결하면 취업규칙에 따라야 한다는 것 그 자체에 즉, 취업규칙의 존재나 내용에 관하여 근로자가 현실적으로 알았는지 혹은 동의하였는지의 여부에 관계없이 당해 사업장에 있어서 근로관계가 발생함과 동시에 취업규칙의 적용을 받게 되는데서 기인한다고 보는 것이다.[20]

이러한 법규범설도 법규범성의 근거를 어디에서 구하는가에 따라 견해가 나뉘고 있다.

우선 소유권설(경영권설)이라 함은 취업규칙의 제정권의 근거를 소유권에

---

17) 石井照久, 勞働法, 青林書院, 228면; 高島良一花見忠: 川崎武夫, 就業規則の效力, 現代勞働法講座 10권, 總合勞働硏究所, 1986, 350면.
18) 石井照久, 勞働法 總論, 有斐閣, 1979, 133면.
19) 이 은영, 위의 논문, 219면.
20) 김 성환・이 상덕・김 정한, [취업규칙분석], 한국노동연구원, 1993, 160면.

연원하는 기업의 경영권에 구하여 취업규칙은 사용자의 기업소유권의 행사에 의하여 설정된 기업경영체의 질서이고, 국가가 이러한 사용자의 지배권능을 승인하여 취업규칙을 경영체의 법규범으로서 간주하는 것이라고 설명하는 것이 소유권설 내지 경영권설이다.[21][22]

이에 따르면 기업경영체가 법적조직체로서 간주되는 결정인 근거는 사용자의 취업규칙 제정에 대한 국가적 수권이며 취업규칙은 경영체의 기본법으로서 국가법과 동일한 효력을 갖는다. 이때 취업규칙이 법령에 위반되지 않고 근로자의기득권을 침해하지 않는 한, 사용자는 작성·변경에 있어서 자유로이 그 권능을 행사할 수 있으며 신법 우선의 원칙에 따라 변경된 취업규칙은 근로자의 동의가 없더라도 우선 적용된다고 한다.[23]

그러나 이 설에 대하여는 기업경영이 자본과 노동의 결합이란 조직으로 행해지는 이상 취업규칙의 필요성을 인정할 수 있으나 조직체에서 근로자의 존재를 무시하고 자본의 기능만을 강조하는 것은 기업소유권의 전제를 허용하는 것으로 부당하다는 비판이 제기 되고 있다.

관습법설[24]이라함은 취업규칙은 사회규범으로서 사실상 근로자를 구속하는 작용을 하고 있기 때문에 관습법에 준 하는 성질을 가지고 있다고 한다. 그리고 이 설은 그 법적 근거에 있어서 국가의 수권으로 보지 않고 취업규칙은 직장 내의 법규범으로서 기득권을 침해하지 않고 강행법과 공서양속을 위반하지 않는 한 근로자의 동의 유무에 관계없이 노사관계의 당사자를 법적으로 구속한다고 설명하고 제정법의 규제에 관계없이 현실적으로 사회규범으로서 기능하고 있는 취업규칙의 규범근거를 '사회 있는 곳에 법이 있다' 라고 하는 명제로 주장한다.[25]

---

21) 津曲藏之丞, 勞動法の基本理論, 131면; 孫田秀春, 勞使關係にねけろ勞動法上の爭點, 226면; 日本最高裁判決, 昭和 27. 7. 4, 勞民集 3권 3호. 275면.
22) 서울民地判 1974. 3. 30, 73가합6032; 서울高判 1976. 4. 2, 75나 2809 참조.
23) 川崎武夫, 전게서, 333면.
24) 김 치선, 노동법강의, 박영사, 1988, 250면.
25) 末弘嚴太郎, 勞働法研究, 407면; 松岡三郎, 條解 勞働基準法(하), 987면: 서울 민지법

그러나 이 설에 대하여 사용자가 일방적으로 작성하고 변경하는 취업규칙에 기업내의 법규범으로서 받아드리는 의식이 존재하느냐 즉, 관습법으로서 성립하기 위하여 필요한 사회규범의식이라는 법적 확신이 존재하느냐에 대한 구체적 근거가 없으며, 직장이라는 부분사회의 규범을 바로 법이라고 인정하는 것은 법개념의 부당한 확대이며 또한 관습에 의하여 성립하지도 않은 취업규칙의 법규범성을 관습법에 관한 법리로 설명한다는 것은 잘못이다라고 비판이 가해진다.[26]

수권설이라함은 사용자가 일방적으로 작성하는 취업규칙은 그 자체로서는 법규성을 가지지 않는 사회규범에 불과하지만 취업규칙 그 자체는 국가법이 노동자보호의 목적으로 특히 법규범으로서 효력을 인정한 것이라고 한다.[27]

이 설은 근기법 제100조의 규정에 근거한 것으로 근기법 제100조가 취업규칙 자체가 갖는 효력을 전제로 하여 법규범성을 창설한 것이 아니고 법이 근로자 보호의 목적으로 취업규칙에 본래 구비되어 있지 않은 효력을 특별히 입법정책적으로 부여한 것이라고 해석한다.[28]

그러나 이 설에 대하여는 다음과 같은 비판이 가해진다. 즉 사용자가 일방적으로 제정하는 취업규칙이 노동자 보호의 목적의 현실을 위하여 법규범의 성격이 부여되고 합의를 거치지 않고 구속력을 가진다는 것은 결국 국가가 사용자에 대하여 노동자보호의 목적을 가지고 노사관계를 규율하는 법규를 제정하는 권한을 부여하고 있는 것이 된다. 그것은 노동자・사용자・국가의 3자간

1974. 8. 30, 73가합6032 판결에서 사업주는 취업규칙에 관한 권리를 가짐이 근기법에 의해 명백한 이상 근로자들의 동의를 얻지 않았더라도 취업규칙의 변경이 법령이 정한 범위 안에서 이루어진 이상 그대로 유효하나 위 취업규칙의 변경에 의하더라도 이미 기득한 퇴직금에 관한 권리를 박탈할 수는 없다고 봄이 상당하므로 기득권의 소급침해라는 범위 안에서 취업규칙 변경은 무효가 되고 변경된 취업규칙은 그 시행일 이후에 한하여 적용될 수 있다고 한다.

26) 이 은영, 위의 논문, 220면.

27) 심 태식, 노동법개론, 1989, 법문사, 396면; 이 병태, 최신 노동법, 중앙경제, 2001, 934면; 本多淳亮, 勞働契約・就業規則論, 東京 一粒社, 1981, 175면.

28) 沼田稻次郎, 就業規則論, 3면; 임종률, 전게서, 316면; 대판 1977. 7. 26, 다 355.

의 상호관계의 입장이라는 측면에서 현재의 노동법의 입법취지와 제도에 있어서 모순이라고 한다. 그리고 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 법규로 인정함은 대등 당사자의 전제로 하는 근대적 계약개념에 반하며 근기법 제100조는 취업규칙과 근로계약의 관계를 정한 것에 불과하고 동조가 사용자에 대하여 법규범의 제정권한을 수권 한 것은 아니라고 한다.[29][30]

3) 그 밖의 논의

독일의 경우 단체협약은 통상적으로 산업별로 체결되어 근로조건의 기준을 형성하는 주된 수단으로 되어 있는데, 산업별로 체결되는 단체협약이 개별사업장의 문제해결에 반드시 충분히 기능한다고는 하기 어려워 사업장내 공동결정제도가 그 보완적 기능을 수행하고 있다. 그런데 19세기말에서 20세기초에 걸쳐서 우리 나라의 취업규칙에 유사한 제도가 있어서 이에 대한 법적 성격을 둘러싸고 논의가 행해진 바 있다. 즉 1891년 6월 1일의 이른바 근로자보호법에 기초하여 영업법 134조 a항 이하 h항이 추가되어 상시 20인 이상의 근로자를 사용하고 있는 모든 사업장에 취업규칙의 제정이 의무화되었다.[31]

---

29) 下井隆史, 就業規則一その法的性質と效力, 恒藤域二編 論爭勞働法, 280-290면; 김 형배 교수가 주장하는 계약설의 입장에 따르면 근기법 제100조는 취업규칙이 갖는 근로자보호기능을 고려하여 취업규칙의 기준에 미달하는 근로계약상의 특약을 무효로 하고 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따르도록 하려는 규정에 지나지 않으며, 취업규칙 자체를 법규범화하려는 규정은 아니라고 한다: 김 형배, 전게서, 209면.

30) 오늘날 일본의 다수설인 이른바 보호법수권설도 보호법수권의 내용을 사용자에게 법규범설정권을 수여한 것으로 이해하지 아니하고, 취업규칙에 법규범적 효력을 부여한 것으로 해석하고 있다: 石井, 新版 勞働法, 1972, 130면; 독일의 경우에 있어서는 사용자에 의한 일반적 근로조건의 설정이 일방적 의무부담부의사표시로서 전체종업원에 대한 약속행위(Gesamtzusage)이므로 일종의 집단법적·형성권적 효력을 가진다는 견해가 있다(Hilger, *Das betrieblich Ruhegeld,* 1959, S. 52; Adomeit, *Rechtsquellenfragen*, S. 112ff.) 그러나 그와 같은 사용자의 행위가 청구권을 창설할 수는 없으며, 독일현행법에 반한다는 이유에서 지배설은 이에 반대한다(Zöllner/Loritz, *ArbR*, 5. Aufl., S.71; Nikisch, ArbR, Bd. I, 3. Aufl., S. 265; *MünchHandbArbR*/Richardi, Bd. 1, Rn. 39 zu §12).

31) 김 재훈, 근로조건 변경의 법리(불이익변경의 한계를 중심으로), 서울대학교 박사학위논문, 1999, 112-113면.

입법제안서에 따르면 취업규칙은 근로관계의 획일적 처리 및 규제화를 통해서 사용자의 자의로부터 근로자를 보호함에 의해 근로자의 이익과 공장경영의 질서유지를 목적으로 하는 것이라고 되어 있었다.[32]

동 법의 제정에 따라 취업규칙의 법적 성격 내지 법적 효과에 관한 논의가 활발히 되었는데, 1891년 법제정 이전에는 취업규칙의 법적 성격에 대해서 계약설이 일반적이었던 것에 비하여 동 법 성립 후에는 법규설이 유력하게 주장[33]되고, 그 가장 주요한 근거로는 취업규칙이 사용자에 의해 일방적으로 공포되어 근로자의 인식 유·무에 관계없이 적용되는 점이 있었다. 즉, 영업법 제134조 c항은 명확하게 취업규칙의 내용은 법률에 위반하지 않는 한 사용자 및 근로자에 대하여 법적 구속력을 지닌다고 정하고 있어서, 각 개별 근로계약에서 취업규칙을 인용하지 않아도 취업규칙은 사용자 및 근로자 전체에 대하여 구속력이 미친다는 점에 해석상 견해의 차이가 거의 없는 관계로 계약설적인 사고방식이 곤란해 졌다.[34]

1952년에 제정되고 1972년에 대폭 개정된 사업장조직법에 따르면 사업장위원회가 사용자와 체결한 사업장협정도 단체협약과 마찬가지로 규범적 효력을 지닌다. 이 점은 사업장자치에 대해서도 협약자치와 마찬가지로 개별적 자치에 대한 우위가 인정된다는 것을 의미한다. 규범적 효력은 강행적 효력과 직접적 효력으로 나뉘어지는데, 강행적 효력이란 사업장협정과 다른 근로조건을 무효로 하는 효력을 직접적 효력이란 근로계약의 당사자인 근로자와 사용자의 의사를 매개로 하지 않고 자동적으로 사업장협정이 적용되는 효력을 의미한다.

---

32) 입법제안서에 따르면 취업규칙에 의해 개별근로자의 계약체결이 용이하게 된다는 점과 경영에 있어서 기술적 경제적 질서가 확립될 수 있다는 점이 열거되어 있다: Motive, Reichstagbericht von 1890, Motive Drucksachen, Nr 4 Anl Bd l. 21면.

33) P Oertmann, rechthche, Natur der Arbeitsordnung, in der Festgabe fur Hubler, 1905, 3면.

34) 手塚和彰, 就業規則の社會的規範としての實態と法的考察, 勞働法の解釋理論, 有斐閣, 1976, 175-176면.

3. 판례의 입장

취업규칙의 법적 성질에 대하여 법원의 입장을 밝힌 대법원 1977. 7. 26, 77다355 판결은 '취업규칙은 사용자가 기업경영권에 기하여 사업장에 있어서의 근로자의 복무규율이나 근로조건의 기준을 획일적·통일적으로 정립하기 위하여 작성하는 것으로서 이는 근기법이 종속적 노동관계의 현실에 입각하여 실질적으로 불평등한 근로자의 입장을 보호·강화하여 그들의 기본적 생활을 보호·향상시키려는 목적의 일환으로 그 작성을 강제하고 이에 법규범성을 부여한 것이라고 볼 것이다'라고 하였다.[35]

위의 판례에 의하면 취업규칙의 법적 성질을 법규범설 중에서 수권설의 입장을 취한 것으로 평가된다. 이 취지는 기본적으로 계속 유지되어 오고 있다.[36][37]

위의 판례에서 취업규칙의 불이익변경과 관련하여 기존 근로조건의 내용을 사용자가 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하는 것은 근기법의 근로자보호법으로서의 이념과 기득권보호의 원칙 및 근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정되어야 한다는 근기법 규정에 반한다고 지적하였다. 그리고 취업규칙의 불이익변경에 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 요구하는 이유로는 집단에 적용되는 법규범의 변경에는 집단적 의사에 의한 동의를 얻게 함으로써 집단전체에 그 효력을 미치게 함이 일반법규범의 변경절차로서 타당하기 때문이라고 하고 있다.

4. 소 결

---

35) 판결 전문은 김치선·김유성, 판례교재 노동법, 법문사, 1987, 244-245면 참조.
36) 심 태식, 전게서, 396면; 임 종률, 취업규칙의 법적 성질과 효력, 김 학수 박사 화갑기념논문집, 1985, 244면; 이 병태, 전게서, 933-934면.
37) 대판 1988. 5. 10, 87다카2578; 대판 1989. 5. 9, 88다카4277; 대판 1991. 2. 12, 90다15952, 15969, 15976.

사용자가 일방적으로 제정하는 취업규칙은 그 자체로서는 계약도 아니고 법규성을 가지지 않는 사회규범에 지나지 않지만, 사실상 근로자들을 구속하며 취업규칙의 변경의 경우에도 근로자들을 구속하고 있다. 이렇게 취업규칙이 노사관계당사자들을 구속한다는 점에서는 계약설이나 법규범설의 차이는 없다. 법규범설의 주요한 논거는 노사간의 실질적인 대등성의 원칙을 관철하기 위해 근기법은 근로자에 대한 보호의 의미가 강하며 이에 의하여 취업규칙은 근로자의 생존권을 보호하고자 하는 제도임을 강조하는데 비하여, 계약설의 입장에서는 사적 자치에 기초하여 근로조건의 문제는 계약적 성질을 그 기초로 하여 사용자와 근로자가 대등한 관계에서 취업규칙에 대한 변경이 있어야 한다는 데에 그 의의가 있는 것으로 보여진다. 즉, 구속력의 근거와 구체적인 시행상의 문제에 있어서 견해의 차이가 있는 것으로 보여진다.

생각컨대 사용자가 일방적으로 제정하는 취업규칙은 그 자체로서는 계약도 아니고 법규범성을 가지지 않는 사회규범에 지나지 않지만 근기법이 근로자보호의 목적에서 보호법원리에 입각하여 취업규칙에 법규범적 효력을 부여하고 있다고 보여진다. 다만 근로자의 생존권에 대한 보호의 의미가 중요함에는 말할 것도 없으나 당사자가 동의하지 않는 것에 대하여 보호라는 이름으로 강요한다면(예컨대 취업규칙의 불이익 변경시 근로자의 동의가 없다하더라도 이른바 '합리성'이론에 의하여 그 변경이 행해지는 경우에 취업규칙이 법규범적 효력을 가지므로 일응 근로자를 구속하게 되는데) 이는 보호라는 본래의 목적에 오히려 역행하는 결과가 나올 수 있다는 점을 간과해서는 아니 될 것이다.

그리고 근기법이 근로계약에 있어서 노·사 대등의 입장에 서면서도 사용자에게 일방적으로 취업규칙의 작성·변경권을 주는 한편 근로조건의 준수의무, 게시의무를 부과하고 행정관청에 신고하도록함과 동시에 불이익 변경시에는 근로자집단의 동의를 얻도록 하고 또한 제재의 한도를 설정한 것 등을 명시한 것으로 보아 전체적인 면에서 살펴보면 취업규칙은 노동보호적 역할을 하는 것으로 보아야 할 것이다.

이에 법적 성질에 관한 여러 견해 중에서 수권설이 타당하다고 고찰된다. 다만 수권설이 근기법 제100조를 수권의 근거[38]로 삼고 있으나 이는 어디까지나 취업규칙의 내용과 한계를 설정한 기준으로서의 규정에 불과한 것이지 '취업규칙이 규범이다'라는 명제를 설명하는 근거로는 될 수 없다고 보여진다.

그리고 계약설이 근로자의 동의를 어떠한 방식으로든 이끌어내어 사용자가 일방적으로 작성하는 취업규칙의 효력에 개별 근로자의 의사를 반영케 하여 공동의 규범에 양자의 의사합치를 도모하려고 한 취지는 이해할 수 있지만 이러한 취지와 달리 그 이론구성이 오히려 사용자의 일방적인 작성·변경을 합법화시키는 결과를 초래할 수 있는 위험이 존재한다고 보여진다.

38) 심 태식, 전게서, 396면.

제3장 취업규칙 변경에 관한 문제점

제1절 개 관

1. 문제의 소재

취업규칙의 변경과 관련하여 문제점으로 논의가 되어 온 것은 취업규칙의 일반적 변경의 경우보다는 불이익변경의 경우이며 이에 취업규칙의 불이익 변경의 문제점을 중심으로 고찰해야 할 것으로 보여진다.

이것을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론과의 충돌문제이다. 취업규칙의 불이익 변경시에는 근로자집단의 동의라는 강행규정이 존재하는데도 불구하고 사회통념상 합리성이 존재한다면 근로자집단의 동의가 없더라도 취업규칙의 불이익변경이 가능하다는 '합리성'이론과의 충돌의 문제는 살펴볼 필요가 있다.

둘째 사용자에 의하여 일방적으로 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력 여부에 관한 것으로 동의를 한 경우에 있어서의 효력과 동의를 하지 않은 경우에 있어서의 효력에 대하여 살펴보기로 한다.

셋째 취업규칙에 변경에 있어서 불이익 변경의 판단기준에 대한 구체적 고찰이 필요하다.

마지막으로 기업변동시 취업규칙의 변경에 관한 문제점으로 기업의 합병이나 양도 등에 있어서 나타나는 취업규칙의 변경 및 승계 등에 관한 문제점을 살펴보기로 한다.

2. 취업규칙의 일반적 변경의 의의

근기법 제97조 제1항 본문에서 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 당해 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있다. 그리고 취업규칙의 작성 또는 변경시에는 노동부장관에게 신고하여야 하는데, 이 경우 제97조 제1항에 따른 근로자집단의 의견을 기입한 서면을 첨부하여야 한다.[39]

이와 같은 규정은 근로자가 사실상의 경제적 또는 사회적 종속성으로 인하여 취업규칙에 따른다는 일반적 관행에 반대할 수 없다는 사정을 고려하여 취업규칙에 대한 국가의 감독조치를 규정한 내용중의 하나라고 볼 수 있을 것이다. 이것은 일본의 경우를 참조한 입법인데 일본 노동기준법 제90조에서는 취업규칙의 작성 또는 변경에 대하여 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 의견을 듣도록 규정되어 있다.[40]

3. 취업규칙의 불이익 변경의 의의

근로자는 통상 보다 나은 근로조건의 획득을 예정하면서 노동조합을 결성하고 다수의 힘을 배경으로 하여 법률상 사용자와 대등한 지위에서의 교섭을 행한다. 그리고 여기서 유리한 협상을 이끌어 내면 일반적으로 근로조건의 향상을 기대할 수 있다. 노사관계는 계속적 성격을 가지는 관계로서 경제·사회적

---

39) 동법 시행규칙 제17조에서는 별지 서식의 취업규칙변경신고서에 취업규칙(변경신고의 경우에는 변경전과 변경후의 내용을 비교하여 기재한 서류)과 근로자의 과반수를 대표하는 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들었음을 입증하는 자료를 첨부하여 관할 지방노동관서의 장에게 제출하여야 한다라고 규정하고 있다.

40) 박 홍규, 노동법론, 삼영사, 1996, 328-329면.

환경에 따라 크게 영향을 받는 것이므로 근로조건의 유동적 형성이 요청되는 것은 당연하다 하겠다.

그러나 일반적으로 근로조건의 향상만이 기대되는 것은 아니다. 기업의 경영상태가 악화되면 사용자는 이를 타개하기 위하여 근로조건의 변경을 가하게 되다. 그러한 수단이 취업규칙의 변경이고 이것은 대부분의 경우에 있어서 근로자에게 불이익한 변경을 초래하게 된다. 하지만 사용자는 일방적으로 취업규칙을 작성할 수 있는 것과 마찬가지로 그 변경도 자유이기 때문에 일정한 요건(취업규칙의 변경시에는 의견청취)만 갖추면 변경을 가할 수 있다. 또한 취업규칙을 사용자가 일방적으로 작성하고 취업규칙의 변경권이 사용자에게 있으므로 사용자가 꼭 필요한 경우가 아니더라도 근로자와의 관계에서 교섭력의 우위를 바탕으로 취업규칙을 불이익하게 변경할 여지가 있게 된다.

이러한 취업규칙의 불이익변경에 관한 판단에 대하여 대법원은 '취업규칙의 변경의 취지와 경위, 해당사업체의 업무적 성질, 취업규칙 각 규정의 전체적인 체제 등 제반사정을 종합하여 판단하여야 한다'[41]라고 하고 있다. 그리고 일부 근로자에게 불리하고 일부 근로자에게는 유리하게 변경되는 경우에 있어서는 제반사항(유리하게 변경된 부분 포함)을 종합적으로 판단하여야 할 것이다.[42]

제2절 근기법 제97조 제1항의 단서와 '합리성'이론

1. 근기법 제97조 제1항의 단서

사용자는 일방적으로 취업규칙을 작성, 변경할 수 있으나 근로자에게 불이익하게 변경 할 경우에는 그 동의를 얻어야 한다. 즉, 사용자가 근로자에게 불이익하게 취업규칙을 변경할 경우 그 변경된 취업규칙이 효력을 발생하기 위

41) 대판 1988. 5. 10, 87다카2853.
42) 대판 1995. 3. 10, 94다18072.

하여는 일반적인 변경의 경우와는 달리 근로자집단의 동의를 필요로 한다.

대법원은 근기법 제97조 제1항 단서[43]가 신설되기 이전부터 근로자에게 불이익한 취업규칙의 변경은 근로자집단의 집단의사결정방법[44]에 의한 동의가 있어야만 변경의 효력이 발생한다고 하고, 다만 근로조건의 변경이 사회통념상 합리성이 있다고 인정된다면 근로자의 집단적 동의를 얻지 않아도 유효하다는 입장을 취하였다.[45] 대법원의 이러한 이론구성은 일본의 최고재판소의 판례이론[46]을 따른 것으로 보이는데, 이는 취업규칙의 변경시 근로자들의 의견청취만을 규정하였던 당시에 있어서는 사용자의 일방적인 취업규칙의 불이익변경을 방지하고, 취업규칙을 통일적으로 적용하는데 크게 기여했다고 한다.[47]

그러나 취업규칙의 변경에 관한 것은 근기법 제97조 제1항의 단서가 규정되면서 오로지 근로자들의 집단적 동의의 유무에 따라 그 효력을 얻을 수 있게

---

43) 근기법 제97조 제1항 단서에서 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 한다 라고 명시하고있으며 이로 인하여 취업규칙의 불이익변경의 문제는 오직 근로자들의 집단적 동의의 유무에 따라 판단되어야 할 것으로 보여지는데 왜냐하면 그것은 근기법 제97조 제1항의 단서가 강행규정이기 때문이다; 이병태, 전게서, 948-949면; 김 형배, 전게서, 215면.

44) 근로자과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노조의 동의가 있어야 하며 노조가 없는 경우에는 근로자과반수의 동의가 있어야 한다.

45) 대판 1978. 9. 12, 78다카1046; 대판 1988. 5. 10, 87다카285; 대판 1989. 5. 9, 88다카4277; 대판 1990. 3. 13, 89다카24780; 대판 1994. 5. 24, 93다14493; 대판 2001. 1. 15, 99다 70846.

46) 김 형배, 전게서, 215면; 일본 최고재판소 昭和 43. 12. 25, 민집 22권 13호; 최고재판소 昭和 58. 11. 25; 최고재판소 63.2.16. [합리성]판단과 관련하여 일본의 최고재판소는 취업규칙의 변경시 그 변경의 내용과 필요성의 양 측면을 고려해야 한다고 하면서 다음의 사항을 고려대상으로 열거하고 있다.

1. 변경에 의하여 종업원이 입게 될 불이익의 정도
2. 변경과 관련해서 행해지는 임금의 개선방안
3. 사내규유의 유지 또는 종업원의 공평한 처우를 위해서 변경이 필요한 것인가의 여부
4. 노동조합과의 교섭의 경위
5. 다른 종업원들의 반응
6. 관련사업체의 규정 등.

47) 김형배, 전게서, 215면.

되었다.

1) 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의

근기법 제97조 제1항 단서에서는 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 한다고 규정하고 있다.

이 규정은 대법원 1977. 7. 26, 77다355판결[48]에서 밝히고 유지되어 온 법리가 1989년 3월 29일 구 근로기준법 개정시 법조문화 되었고, 1997년 3월 13일 새로운 근로기준법의 제정시 제97조로 규정되기에 이른 것이다.

취업규칙의 불이익변경에 이와 같이 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 그 요건으로 부과하는 것은 위 최초의 판례에서 밝히고 있는 바와 같이 취업규칙을 파악하여 일반법규범의 변경절차와 같이 집단에 적용되는 법규범의 변경에는 집단적 의사에 의한 동의를 얻게 함으로써 집단전체에 그 효력을 미치게 하기 위한 취지라고 고찰된다.

그리고 취업규칙에서 근로조건에 관한 결정에 있어서 그 동의의 주체는 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단이다. 따라서 개별근로자는 동의의 주체가 아니며 취업규칙의 불이익한 변경에 개별적으로 동의한 근로자에 대하여 그 변경의 효력은 인정되지 않는다. 만약에 취업규칙의 불이익한 변경에 개별적으로 동의한 근로자에 대하여 그 효력을 인정하게 된다면 하나의 사업장에 다수의 취업규칙이 병존하게 되어 획일적·통일적 적용을 필요로 하는 취업규칙제도의 취지에 반하게 된다고 본다.

---

48) 위 판결에서 근기법의 보호법으로서의 정신, 기득권보호의 원칙 및 근기법 제3조, 제98조(1977년)의 규정 등에 비추어 취업규칙의 변경에 의하여 기존 근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받고있던 근로자 집단의 집단의사 결정방법에 의한 동의를 요하며 이와 같은 동의가 없는 한 취업규칙의 불이익한 변경에 대하여 개인적으로 동의한 근로자에 대하여도 그 변경의 효력은 발생되지 않는다 라고 판시하였다.

2) 동의의 방식

현행 근기법 제97조 제1항 단서에서는 근로자 집단의 의사결정방식에 의한 동의의 방식에 대해서는 구체적으로 규정해 놓고 있지 않고 있다. 대법원의 견해에 따르면 부서별·기구별 의견취합방식도 허용된다고 하여 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우 요구되는 집단적 의사결정방법이라 함은 반드시 한 사업 또는 사업장의 모든 근로자가 일시에 한자리에 집합하여 회의를 개최하는 방식만이 아니라 한 사업 또는 사업장의 기구별 또는 단위부서별로 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 상호간에 의견을 교환하여 찬반의견을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다고 한다.[49]

노사협의회에 의한 동의의 경우에 대하여 대법원의 판결은 회사 노사협의회의 규정에 임금·근로시간 등의 근로조건에 관한 사항까지 협의·결정할 수 있는 것으로 규정되어있다. 그리고 퇴직금규정의 불이익변경은 노사협의회 근로자위원들의 동의를 얻은 경우에 관하여 노사협의회는 근로자와 사용자 쌍방이 이해와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로서 산업평화를 도모할 것을 목적으로 하는 제도로 보고 있다. 그리고 이러한 노사협의회는 노동조합과는 그 제도의 취지가 다르므로 비록 회사가 근로조건에 관한 사항을 그 협의사항으로 규정하고 있다 하더라도 근로자들이 노사협의회를 구성하는 근로자위원들을 선출함에 있어서 그들에게 근로조건을 불이익하게 변경하는데 근로자들을 대신하여 동의를 할 권한까지 포괄적으로 위임한 것으로 볼 수 없다고 대법원은 밝히고 있다.[50]

회람형식으로 근로자의 동의를 얻은 경우에 취업규칙을 근로자들에게 불리하게 개정하면서 근로자 상호간의 아무런 의견교환과정 없이 회사와 근로자들간에 개별적으로 논의를 한 후 회람형식의 동의서에 근로자들이 개별적으로

---

49) 대판 1992. 2. 25, 91다25055; 대판 1993. 1. 15, 92다39778.
50) 대판 1994. 6. 14, 92다 28556.

동의한다는 취지로서 날인한 경우에는 집단적 의사결정방법에 의한 동의라고 볼 수 없다고 한다.[51][52]

한편 취업규칙의 불이익변경에 필요한 노동조합의 동의에 있어서 조합장의 동의가 아닌 조합소속 근로자 과반수의 동의가 필요한지의 여부에 대하여 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 회사에서 정년규정을 신설하여 근로자에게 불이익하게 취업규칙을 변경하는 경우 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어야 하는 바, 이러한 노동조합의 동의는 법령이나 단체협약 또는 노동조합의 규약 등에 의하여 조합장의 대표권이 제한되었다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한, 조합장이 노동조합을 대표하여 하면 되는 것이지 노동조합소속 근로자의 과반수의 동의를 얻어서 하여야 하는 것은 아니라고 하고 있다.[53]

상술한 대법원의 견해를 토대로 동의에 방식에 대하여 첫째 부서별·기구별 의견취합방식을 허용하는 판례의 취지는 사업장의 업무의 특성[54]이나 사업장의 분산으로 인하여 전체근로자의 회의방식에 의한 동의를 얻는 것이 사실상 어려울 때 최소한 이와 같은 방식으로라도 근로자집단의 동의를 얻도록 하는 취지에서 인정된 것으로 보여진다.

둘째 노사협의회에 의한 동의의 경우를 부정한 판례의 취지는 노사협의회와 노동조합은 그 설립목적, 협의사항 내지 교섭사항, 사용자에 대한 교섭력에 있

---

51) 서울 민지법 1994. 12. 22, 94가합65189 판결.

52) 회람형식이나 확인서 방식으로 개별근로자의 동의를 얻고 있는 이와 같은 경우 직원들은 보수규정 개정에 관하여 자유로이 의견을 교환할만한 기회를 갖지 못하게 되며, 회사의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 상호간에 의견교환을 거쳐 자주적으로 이루어진, 근로자집단의 집단적 의사결정에 의한 동의라고 볼 수 는 없게 되기 때문에, 그 동의가 유효하다고는 볼 수 없다고 하겠다; 법률신문 1995. 7. 13, 11면.

53) 대판 1997. 5. 16, 96다2507.

54) 대판 1993. 8. 27, 93다16895; 당해 사업장이 방송매체이므로 근로자집단의 동의를 얻는 것이 불가능하였다고 회사측이 주장하였지만, 판례에서는 기구별·부서별 의견취압방식까지 불가능하였다고 볼 수는 없다고 하였다.

어서 차이가 있는 것으로 노사협의회에는 사용자측의 개입이나 간섭을 배제한 상태에서 사용자와 대등한 지위를 확보할 수 있는 제도적 보장이 이루어져 있지 않기 때문에[55] 노사협의회에는 취업규칙 불이익변경에 대한 동의권한이 인정되지 아니한다고 할 것이다.

셋째 근로자 상호간의 아무런 의견교환과정 없이 회사와 근로자들간에 개별적으로 논의를 한 후 회람형식의 동의서에 근로자들이 개별적으로 동의한다는 취지로서 날인한 경우에는 집단적인 의사결정방법에 의한 동의라고 볼 수 없다 할 것이다.

마지막으로 노동조합의 조합장의 동의권에 대하여 판례의 취지는 '노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다'는 노동조합 및 노동조정관계법 제29조 제1항을 염두에 둔 것으로 보여진다.[56][57]

2. '합리성'이론

취업규칙의 불이익변경은 근로자집단의 동의를 요함은 앞서 살펴 본 바와 같다. 그런데 대법원은 취업규칙의 변경에 있어서 "근로조건의 변경이 근로자의 동의를 받지 않아도 될 사회통념상 합리성이 있다고 인정될 수 있다면 취업규칙의 변경은 유효하다."[58]라고 하여 취업규칙의 변경시 근로자집단의 동

---

55) 김 선수, 취업규칙의 불이익변경과 노사협의회의 동의, [월간 노동법률], 1994년 9월호, 14면 참조.

56) 대판 1997. 5. 16, 96다2507; 대판 2000. 9. 29, 99두10902: 김형배, 전게서, 212면.

57) 이에 대하여 김 유성 교수는 노동조합의 민주성 확보라는 견지에서 노동조합의 대표자의 협약체결권에 대한 제한으로서 인정되지 않는 것이 당해 권리를 형해화하는 것, 즉 전면적·포괄적 제한에 한정되어야 한다고 하며 총회 인준권조항이 조합대표장의 협약체결권에 대한 전면적·포괄적 제한에 해당하여 효력이 부인되는 경우에도 부인되는 효력의 범위는 대사용자관계에 한정되어야 한다고 비판을 제기하고 있다; 김 유성, 전게서, 134-136면.

58) 대판 1978. 9. 12, 78다1046; 대판 1990. 3. 13, 89다카24780; 대판 2002. 6. 11, 2001다16722에서는 사용자가 일방적으로 새로운 취업규칙의 작성·변경을 통하여 근로자가

의가 없더라도 '합리성'이 있다면 즉, 취업규칙을 불이익하게 변경할 수밖에 없었던 사회통념상의 합리성이 존재한다면 취업규칙의 불이익변경이 인정된다고 보고 있다.

그러나 현행 근기법 제97조 제1항의 단서에 의하면 이러한 '합리성'이론은 강행규정에 반하는 것이 된다. 그러함에도 '합리성'이론이 적용되는 것은 무엇인가?

1) '합리성'이론의 도입

앞서 살펴본 바와 같이 대법원은 일본의 최고재판소의 법리를 수용한 것으로 보여지며 1978년 이후 다음과 같은 판결이 현재까지 계속되고 있다. 살펴보면 "근로조건의 변경이 근로자의 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상 합리성이 있다고 인정될 수 있다면 취업규칙의 변경은 유효하다." 라고 하고 있다.[59]

일본 최고재판소는 앞서 상술한 내용을 바탕으로 이후의 판례[60]를 통하여 취업규칙 불이익변경의 구속력을 변경의 합리성 유무에 의해 판단하는 구조를

가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이나, 당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 할 것이고, 한편 여기에서 말하는 사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등 관련된 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

59) 대판 1988. 5. 10, 87다카2853; 대판 1989. 5. 9, 88다카4277; 대판 1990. 3. 13, 89다카24780; 대판 1993. 1. 15, 92다39778; 대판 1993. 8. 24, 93다17898; 대판 1993. 8. 27, 93다16895; 대판 1997. 5. 16, 96다2507; 대판 2002. 6. 11, 2001다16722.

60) 秋北버스사건, 최고재판소 1968. 12. 25 판결.

확정시키고 그 판단기준을 분명히 하였는데, 이에 따르면 취업규칙 불이익변경의 합리성은 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그것에 의해 근로자가 입게 되는 불이익의 정도를 고려하여도 당해 조항의 법규범성을 시인할 수 있을 정도의 합리성을 지닌 것을 말하며, 임금·퇴직금 등 근로자에게 중요한 근로조건에 관한 불이익변경에 대하여는 당해 조항을 근로자에게 법적으로 수인하게 하는 것을 허용할 수 있을 정도의 고도의 필요성에 기초한 합리적 내용일 것을 요한다.

즉 취업규칙 불이익변경의 구속력에 대한 일본에서의 판례는 당해 변경의 내용과 변경의 필요성과의 비교형량을 기본으로 하면서, 불이익의 정도·내용을 충분히 고려하면서 동시에 변경의 사회적 상당성의 원칙을 중심으로 하여 노동조합과의 교섭과정, 기타 종업원의 태도 등도 감안하는 것으로 말할 수 있다.[61][62]

여기서 중요시되는 것이 사회적 상당성에 관한 원칙인바 다음에서는 사회적 상당성의 원칙에 대하여 살펴보기로 한다.

2) '합리성'이론에서의 사회적 상당성의 원칙

사회적 상당성의 원칙은 법의 일반원칙으로 주로 형법 및 민법이론에서 논의되고 있는데, Bulla에 의하면 이 원칙은 노동법영역에서도 결코 새로운 것은 아니고 이미 학설·판례에 의해 전개되어 독일 노사관계의 사회적 질서에서 독자적인 구성요소로 되어 있다고 한다.[63]

즉 노동법의 영역에서 이 원칙은 구체적인 역할로 법률해석의 원칙, 법률감

---

61) 菅野和夫, 勞働法 제4판, 弘文堂, 101-102면.

62) 하지만 취업규칙의 불이익 변경에 대하여 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 규정하고 있는 근기법 제97조 제1항의 단서가 신설된 이후의 이 문제에서는 동 조항이 강행규정이므로 오직 그 동의여부에 따라 판단되어야 한다는 비판이 제기 되고 있다; 김 형배, 전게서, 215면; 이 병태 교수도 위의 '합리성' 이론을 그대로 수용하는 것은 타당하지 않다고 하고 있다 이 병태, 전게서, 949면.

63) Bulla, Das Prinzip der Sozialadaquanz im Arbeitsrcht, *RdA* 1962, Heft 1, 9면.

시원칙, 법률수정원칙 기능을 행하고 있다면서, 구체적으로 해고제한의 원칙적 기준[64], 불확정개념에 대한 해석기준, 평등취급의 원칙·유해위험근로에 있어서 책임제한·근로자가 반입한 물건에 대한 배려의무 등 노동법상 제도에 있어서 일반적인 기준으로서 기능하고 있다고 설명하고 있다.[65]

우리 나라의 경우에도 사회적 상당성이라는 개념은 쟁의행위의 정당성의 판단, 전직명령의 정당성 판단, 휴직처분의 정당성 판단, 해고의 정당성 판단 등 개별적 근로관계·집단적 노사관계에 걸쳐 전제로 되고 있는 기준이기도 하다.[66]

생각해보면 사회적 상당성 이론은 단적으로 말하여 행위의 사회적 의미를 탐구하여 사회적으로 상당한 행위를 정당한 행위로 하는 것이지만, 공공의 복리와 사회적 목적을 강조하는 권리남용금지원칙과 연계되어 있다고 보여진다. 그리고 이러한 이론을 토대로 대법원은 근로자집단의 동의가 없더라도 사회적 합리성이 존재한다면 불이익한 취업규칙의 변경도 가능한 것으로 보고 있다.

제3절 취업규칙 변경의 효력상의 문제점

변경된 취업규칙은 그것이 법령 또는 단체협약이나 사회질서에 반하지 않는 이상, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 동의를 얻으면 유효하게 변경되어 효력을 발생한다. 취업규칙의 변경의 효력에 있어서 특히 문제점으로 인식되어온 것이 취업규칙의 불이익변경에 관한 것으로 근로자집단의 동의의 유무에 따라서 그에 대한 효력상의 문제점이 발생할 수

64) 독일 해고제한법 제1조 제2항은 사회적으로 부당한 해고는 무효라고 전제하면서, 사용자의 해고가 근로자의 일신상의 사유, 근로자의 행태상의 사유, 긴박한 경영상의 필요에 의하지 않고 행해진 해고는 이를 사회적으로 부당한 해고라고 하고 있다.
65) Bulla, 위의 논문, 9-11면 참조.
66) 김 재훈, 위의 논문, 129면.

있다. 그리고 취업규칙의 불이익변경에 대한 근로자집단의 동의 없이 취업규칙을 변경한 후에 단체협약을 통해 사후 동의를 받은 경우에 이에 대한 효력에 있어서의 문제점은 단체협약과 취업규칙이라는 관계를 정립함에 있어서 난점이 존재할 것으로 보여진다.[67]

노동조합이란 원래 근로자의 근로조건의 향상을 목적으로 하여 결성된 근로자의 자주적 단결체이므로 단체협약을 통하여 조합원의 근로조건을 저하시키는 것이 가능하다고 볼 것인가라는 의문이 든다. 그리고 취업규칙은 조합원만이 아니라 비조합원에게도 일률적·정형적으로 적용되는 사업장내 법규범이므로 불이익 변경된 취업규칙에 대한 단체협약상의 동의로 인하여 취업규칙이 유효하게 된다면 그 동의과정에 참가하지도 아니한 비조합원까지 일방적으로 구속을 받고 불이익을 당한다는 점에서 그 효력을 무조건적으로 인정할 수 있는가 하는 문제가 있게 된다.

1. 집단적 동의를 얻은 경우

1) 단체협약에 의한 동의의 경우

근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻음으로써 불이익한 취업규칙의 변경이 효력을 발생하게 되는데 이 경우 그 변경에 반대하는 근로자에 대해서도 불이익변경의 효력이 미치게 되는 것은 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 일반법규범의 변경절차로 보아 그 효력이 반대하는 자에게도 미치게 되는 결과로 풀이된다.

그런데 단체협약에 의한 동의를 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의로 볼 수 있는지 하는 점이 문제로 제기된다.

---

67) 다만 이에 대하여 근기법 제99조 이하에서 규정하고 있는바 살펴보면 근기법 제99조에서는 취업규칙은 법령 또는 당해 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없으며 노동부 장관은 법령 또는 단체협약에 저촉되는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다라고 하고 있다.

이 점에 대하여 대법원 1997. 8. 22, 96다6967판결에서는 취업규칙 중 퇴직금지급률에 관한 규정의 변경이 근로자에게 불이익함에도 불구하고 사용자가 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 아니한 채 변경을 함으로써 기득 이익을 침해하게 되는 기존의 근로자에 대하여는 종전의 퇴직금지급률이 적용되어야 하는 경우에도 노동조합이 사용자측과 사이에 변경된 퇴직금지급률을 따르기로 하는 내용의 단체협약을 체결한 경우에는 기득 이익을 침해하게 되는 기존의 근로자에 대하여 종전의 퇴직금지급률이 적용되어야 함을 알았는지 여부에 관계없이 원칙적으로 그 협약의 적용을 받게 되는 기존의 근로자에 대하여도 변경된 퇴직금 지급률이 적용되어야 한다고 하고 있다.

이러한 입장은 동일한 내용의 근로조건의 변경의 경우에 유리한 조건 우선원칙을 부정하는 견해로 취업규칙의 변경절차에 대해서는 효력이 부정되고 단체협약에 의해서는 그 효력인 인정된다는 것으로 이는 결과적으로 협약당사자의 의사에 반하는 것이 되어 부당하다.

그리고 단체협약이 유리한 개별약정을 승인하고 있다든가 혹은 협약의 변경자체가 신뢰보호의 원칙에 반하는 것으로 그 효력이 부정되는 것과 같은 경우에는 비조합원이라도 취업규칙에 의해 권리주장을 할 수 있다고 해야 할 것이다. 신뢰보호의 원칙은 구체적으로는 협약의 소급적 불이익변경의 금지, 이미 발생한 청구권의 보호, 기대권의 보호가 포함된다.[68]

이와 관련하여 퇴직금채권은 일정기간의 경과를 발생사유로 하여 근로관계의 존속중에 이미 발생하고 있지만 그 이행기가 퇴직이라는 불확정기간에 있는 것이라고 한다면, 퇴직금지급률의 변경을 위해서는 개개 근로자의 수권이 필요하다든지 노동조합 내부에 있어서의 토론을 거쳐 노동조합대회와 조합원투표 등에 의해 그 의사가 사용자와 노동조합의 교섭과정에 반영되어야 한다고 고찰된다. 이러한 해석은 노동조합대표자의 협약체결권에 대한 전면적・포

---

68) R Richardi, *Kollektivgewalt und Indwtdualwille bei der Gestaltung des Arbeitsverhaltrusses,* 1968, S 428ff, H Wiedemann, *Tarifvertragsgesetz*, 5 Auf, 1977, S 139ff; 手塚勝利, 集團的勞使關係秩序と就業規則・勞動協約の變更法理, 季刊勞働法, 제150호, 1989, 143면.

괄적 제한에 해당하지 아니한다고 볼 것이다.

그리고 취업규칙 불이익변경에 대한 단체협약에 의한 동의에 있어서 단체협약이 사업장단위의 효력확장제도에 의하여 그 효력이 확장되는 경우 비조합원에 대해서도 불이익변경의 효력이 미칠 것인지 하는 점이 문제로 될 수 있다.

즉, 이 경우 유리원칙의 적용여부가 문제로 되는 것인데, 사업장단위의 효력확장제도는 소수근로자 보호를 위하여 법이 특별히 인정한 제도로서 근로조건을 획일화하는데 목적이 있는 것이 아니라고 할 때, 확장되는 단체협약상의 근로조건은 표준적 기준으로서 작용하는 것이 아니라 최저기준으로서 작용한다고 보아야 하므로, 협의 효력이 확장되는 경우에는 유리원칙이 적용된다고 고찰된다.[69]

2) 비조합원에 대한 불이익 변경된 취업규칙의 적용여부

근로자의 기득의 권리를 침해하지는 않으나 임금, 근로시간, 퇴직금지급률 등 기존의 근로조건을 장래에 향하여 불이익하게 변경함으로써 단체협약에 의한 동의가 있는 경우에는 주로 유리의 원칙(Günstigkeitsprinzip)의 인정여부로 논하여지고 있다.

우리 나라에서는 유리의 원칙의 인정여부에 대하여 단체협약에 양면적 강행성까지 인정함은 불필요하고 부적당하다는 점, 협약자치와 개인근로자의 자유영역을 조정하는 매개체로서 유리원칙은 인정되어야 한다는 점 등을 이유로 이를 긍정하는 견해[70]와 노동조합의 독점적 통제력을 강화함으로써 노동조합주의에 충실하고자 이를 부정하는 견해[71]로 나뉘어져 있다.[72][73]

---

69) 김 유성, 전게서, 188-193면.

70) 김 유성・이 홍재, 노동법2, 한국방송통신대학출판부, 1993, 159면; 김 형배, 전게서, 122면・629-631면.

71) 김 수복, 노동법, 중앙경제, 1991, 786면.

72) 유리의 원칙(Günstigkeitsprinzip)과 관련하여 김 형배 교수는 사용자가 자발적으로 단체협약의 기준보다 유리한 급부를 하거나 또는 근로계약에 의하여 단체협약의 기준 이상의 급부를 약속하는 것은 유효하며, 단체협약의 조항과 다른 약정은 그것이 근로자들에게 유리한 경우에는 유효한 것으로 하고 있다: 김 형배, 전게서, 629면.

그러나 조합원에 대한 위와 같은 논의가 비조합원에 대하여 그대로 타당한 것은 아니라고 보여진다. 왜냐하면 비조합원에게는 단체협약에 의한 동의에 기하여 불이익 변경된 취업규칙이 구속력을 가지는지 여부가 문제될 뿐 조합원에 대한 적용을 원칙으로 하는 단체협약의 양면적 강행성 인정여부는 아무런 관련이 없는 것이기 때문이다.

한편 근기법 제100조를 근거로 하여 개별근로계약과 취업규칙 사이에도 유리원칙을 인정할 수 있다고 볼 수도 있다. 그러나 동 조항은 취업규칙에 달하지 않는 근로계약의 내용을 무효로 하면서 취업규칙에 보통적 효력을 인정한 것에 지나지 않고 취업규칙이 근로계약에 미달하는 근로조건을 정하여서는 안된다는 취지로 볼 수는 없다. 만약 그렇게 본다면 근로자집단의 동의를 얻은 취업규칙의 불이익변경 자체를 봉쇄하는 것이 되기 때문이다.

요컨대 과반수 이상의 근로자로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약에 의한 동의를 취업규칙의 불이익변경에 대한 적법한 동의로 인정하는 것은 비록 비조합원이 동의절차에 참여할 수 없는 난점이 있다고 하여도 이미 근기법 제97조 제1항의 단서가 예정하고 있는 것이라 볼 것이다.

다음으로 퇴직금지급률이나 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금의 산정기준을 소급하여 불이익하게 변경한 취업규칙에 대하여 노동조합이 단체협약을 통하여 동의한 경우와 같이 근로자의 기득의 권리를 침해하는 불이익변경된 취업규칙의 비조합원에 대한 적용을 긍정할 것인지가 문제이다.

대법원은 조합원 및 비조합원에 대하여도 그 적용을 인정하는 취지로 판시하고 있다.[74] 이와 관련하여 노동부의 행정해석이 있는바, 살펴보면 비조합원

---

73) 단체협약의 기준을 최저기준이라고 생각하지 않고 전반적 노동력거래의 절대적 표준이라고 보는 견해가 있다 이 견해에 의하면 단체협약상의 기준을 상회하는 내용을 가진 개별적 특약을 체결하는 것은 노동조합활동의 약화를 초래하고 부당노동행위를 성립시킬 가능성이 있다고 한다. 따라서 이 견해에 의하면 단체협약상의 기준보다 불리한 것은 물론 유리한 특약도 노조법 제33조에 위반하는 것으로 보는 것이며, 결과적으로 유리한 조건 우선의 원칙을 부인한다: 박 홍규, 전게서, 778면; 沼田稻次郎, 改訂版 勞働法要說, 226면; 山口造一郎, 勞働組合法, 1983, 167면.

74) 앞의 대법원 판결: 노동조합이 사용자측과 기존의 임금, 근로시간, 퇴직금 등 근로조건을 결정하는 기준에 관하여 소급적으로 동의하거나 이를 승인하는 내용의 단체협약을

에 대한 성과배분제, 연봉제 도입시 취업규칙의 불이익한 변경이 문제된 경우 동의를 받아야 하는 대상에 대하여 노동부는 '취업규칙 변경시 그 내용이 불이익한 변경이라고 판단되는 경우에는 이의 적용을 받는 해당 직원의 과반수 이상으로부터 동의를 받는 외에, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 그러한 노동조합이 없다면 근로자의 과반수의 의견을 청취하면 된다'라는 내용의 해석을 여러 차례 회시하고 있다.[75]

이는 비조합원들만을 대상으로 하는 취업규칙의 불이익변경은 당해 비조합원들 입장에서는 불이익 변경이므로 이들 과반수의 동의를 얻어야 된다고 보는 한편, 나머지 다른 근로자들 입장에서는 유리하지도 불리하지도 않은 취업규칙의 단순변경에 해당되므로 이와 관련하여서는 과반수 조합 내지는 근로자 과반수의 의견을 들어야 한다는 의미로 풀이된다. 또한 위와 같은 해석은 사용자로 하여금 취업규칙 적용 당사자의이익과 집단적 의사를 동시에 고려하게 하려는 취지가 담겨져 있는 것으로 해석된다. 그러나 근로자에게 불이익하지 아니한 취업규칙 변경시 사용자가 근로자집단으로부터의 의견청취 의무를 위반하는 경우 근로기준법상의 벌칙 적용 유무는 별론으로 하더라도 이러한 의무위반이 취업규칙의 효력자체를 상실시키는 것은 아니라고 해석되고 있다는 점[76]을 감안한다면 의견청취의무를 추가한다는 것이 변경된 취업규칙의 효력에 있어서 별다른 의미를 가지지는 못할 것이다.

3) 불이익 변경의 소급효 문제

체결한 경우에 그 동의나 승인의 효력은 단체협약이 시행된 이후에 그 사업체에 종사하며 그 협약의 적용을 받게 될 노동조합원이나 근로자들에 대하여만 생기고, 단체협약 체결 이전에 이미 퇴직한 근로자에게는 위와 같은 효력이 생길 여지가 없다.

75) 노동부 행정해석, 근기법 68207-2117, 1998. 8. 31; 근기법 68207-108, 1999. 9. 22; 근기법 68207-988, 2000. 3. 31.

76) 대판 1994. 12. 23, 94누3001: 동 판결에서는 단체협약에서 취업규칙의 작성·변경에 관하여 노동조합의 동의를 얻거나 노동조합과의 협의를 거치거나 그 의견을 듣도록 규정하고 있더라도 원칙적으로 취업규칙상의 근로조건을 종전보다 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우가 아닌 한 그러한 동의나 협의 또는 의견청취 절차를 거치지 아니한 채 작성·변경한 취업규칙의 효력이 부정되지 않는다고 판단하고 있다.

취업규칙이 근로자들의 동의를 얻어서 불이익하게 변경된 경우 그 효력은 그 동의시부터 발생하고, 동의 이전까지 소급하여 미칠 수는 없다. 취업규칙을 법규범설적인 입장에서 파악하거나, 계약설적인 입장에서 파악하는 경우에도 전자의 경우에는 소급효가 발생할 여지가 없고, 후자의 경우에는 동의시에만 효력이 발생할 여지가 있게된다.

대판 1990. 11. 27, 89다카15939에서 퇴직금 지급률에 관한 취업규칙이 근속기간에 따른 누진제에서 단수제로 변경되어 시행된 경우, 변경 이전에 입사하였다가 변경이후에 퇴사한 근로자들의 퇴직금을 산정함에 있어서 입사일로부터 변경전까지의 재직기간에 대한 퇴직금지급률에 대해서는 종전 취업규칙을 그 이후 퇴사일까지의 재직기간에 대한 퇴직금지급률에 관해서는 변경된 취업규칙을 각 적용하였는데, 판결은 취업규칙의 불이익변경에 대한 근로자들의 동의가 있었다고 하여도 그것만으로는 불이익하게 변경된 취업규칙이 종전 재직기간에 대하여까지 소급적용된다고 볼 수 없다고 하여 이 법리에 입각하고 있다.

그런데 이와 같은 취업규칙 불이익변경의 소급효 문제는 근로자들의 집단적 동의 없이 불이익 변경된 취업규칙 규정에 대하여 단체협약에 의해서 소급적 동의를 할 수 있는지 여부와 관련하여서도 논의된다.

이에 대해 대판 1992. 7. 24, 91다34073 에서는 '노동조합이 사용자와 체결한 단체협약 부칙에 단체협약 시행일 이전에 발생한 모든 사항은 이 협약에 의한 것으로 본다'라고 규정한 경우 이 단체협약에서 특별히 퇴직금지급률의 변경을 위한 취업규칙의 개정에 관한 사항을 배제하는 내용의 규정을 두지 않았으므로 노동조합은 위 단체협약에 의하여 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 못하여 무효인 퇴직금지급률의 변경에 관해서도 소급적으로 동의한 것이라고 해석해야 할 것이고, 이와 달리 위 단체협약 부칙의 의미를 장래에 대해서만 효력을 승인한 것이라고 볼 것은 아니라고 하고 있다.

위 대법원 1992. 7. 24, 91다34073 판결의 원심인 서울고법 1991. 8. 30, 91나

20830 판결은, 이와 같은 협약규정의 취지는 위 단체협약 시행일 이전에 취득한 근로자의 기득권을 소급하여 박탈하는 것이 아니라 장래에 향하여 개정된 퇴직금 지급규정의 효력을 승인한 것에 불과하다고 해석함이 상당하다고 보고 있다

그리고 대판 1992. 11. 24, 91다31753에서는 근로자집단의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의가 있으면 취업규칙의 불이익변경은 유효하다고 할 것인데, 이는 취업규칙의 변경에 의하여 기존의 근로조건이나 근로자의 권리를 소급하여 불이익하게 변경하는 경우에도 마찬가지라고 한다.[77]

위 대법원 1992. 11. 24, 91다31753 판결의 원심인 서울고법 1991. 7. 19, 90나42420 판결은, 회사와 노조간의 합의가 퇴직금누진제의 적용을 받고 있던 근로자의 기득권을 소급하여 침해하는 내용을 담고 있으므로 당해 근로자의 동의나 다른 특별한 사정이 없는 한 회사와 노동조합의 합의만으로 근로자의 구체적 기득권을 침해할 수 없다고 밝히고 있다.

아울러 대판 1997. 8. 22, 96다6967에서는 취업규칙상 퇴직금지급률을 인하함에 있어서 근로자의 집단적 동의 없이 행하여 무효이었는데 그 후 단체협약에서 '퇴직금 지급률은 회사측 규정에 따른다'고 규정한 경우, 이러한 내용의 단체협약을 체결함으로서 그 단체협약의 적용을 받게 되는 취업규칙 변경전의 기존근로자에 대하여도 단체협약 체결 당시의 법규적 효력을 가지는 개정규정의 퇴직금지급률을 적용하는 것에 대하여 소급적으로 동의한 것으로 보아야 할 것이므로, 단체협약 체결당시 기존의 근로자에 대하여 개정규정의 퇴직금 지급률이 적용되지 아니함을 알았는지 여부에 관계없이 위 단체협약이 시행된 이후에 퇴직하는 근로자들에 대한 퇴직금을 산정함에 있어서는 개정규정을 적용하여야 한다고 밝히고 있다.

위 대법원 1997. 8. 22, 96다6967 판결의 원심인 서울고법 1995. 12. 21, 95나12578 판결에서 노동조합이 단체협약 체결당시 개정규정의 퇴직금지급률에 관한 조항이 무효라는 점을 알면서 위와 같은 단체협약을 체결하였다고 인정할

77) 같은 취지의 판결로는 대판 1994. 5. 24, 93다46841 이 있다.

증거가 없으므로 개정규정 중 퇴직금지급률에 관한 조항의 효력을 소급적으로 추인하였다거나 개정규정의 유·무효간에 그 효력을 인정하기로 동의한 것으로 볼 수 없다고 하고 있다.

이와 같은 판례의 입장에 대하여 퇴직금이 임금후불적이 성격을 지닌다는 점, 동의의 소급효를 인정하게 되면 근로자들의 기득의 권리를 침해하게 된다는 점, 신뢰이익의 침해가 있게 된다는 점에서 보아 타당하지 않다고 한다.[78]
그러나 취업규칙의 변경은 그것이 유리한 것이든 불이익한 것이든 단체협약에 의하여 동의가 이루어진 경우에는 그 단체협약의 협약기준이 근기법상 위배되지 않을 때는 변경된 취업규칙은 유효하다고 할 것이다.

한편 퇴직금규정의 하향조정 후 사후에 노동조합에 의한 추인을 받는 경우 판례[79]는 추인 당시에 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있으면 설사 그것이 취업규칙의 불이익변경 후 설립되었거나 그 개정으로 불이익을 입은 근로자들 중 일부는 추인 당시 승진 등의 이유로 노동조합 가입자격을 상실한 상태였고 실제에 있어서 그 개정으로 불이익을 입는 근로자들 중 노동조합에 가입한 근로자가 전혀 없다고 하더라도 마찬가지라고 밝히고 있다.

2. 집단적 동의를 얻지 못한 경우

1) 개별적 동의가 있는 경우

근기법 제97조 제1항의 규정에 따라 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 불이익변경은 무효로 된다. 이와 같은 집

78) 김 형배, 전게서, 216면; 김 유성, 전게서, 168면; 이 병태, 전게서, 949-950면; 박 홍규, 전게서, 355면.
79) 대판 1995. 4. 21, 93다8870; 대판 1997. 2. 11, 95다55009.

단적 동의를 얻지 못한 경우, 개인적으로 동의한 근로자에 대하여도 변경의 효력이 발생하지 아니한다.[80] 이 경우 가령 근로자가 사용자인 회사로부터 불이익하게 개정된 퇴직금규정 등의 내용을 통보 받고도 아무런 이의 제기도 하지 않고 그대로 근무한 것을 개정된 퇴직금규정 등에 대하여 개인적으로 묵시적인 동의를 한 것으로 본다고 하더라도 개정된 퇴직금규정 등의 효력은 그 근로자에 대하여도 미치지 아니한다.[81] 이는 취업규칙의 법적 성질을 법규범설로 파악한 대법원 1977. 7. 26, 77다355 판결이후 확립된 판례의 태도라고 볼 수 있다.

위 대법원 판결은 취업규칙의 불이익한 변경에 개인적으로 동의한 근로자에 대하여는 그 변경의 효력이 있고 동의하지 아니한 근로자에 대하여는 효력이 없다고 한다면 근로자는 단체로서 행동할 때 실질적으로 사용자와 대등한 입장에 서게 된다는 것이 모든 노사관계법의 기본입장이므로 사용자는 실질적으로 대등하지 아니한 우월한 지위에 서서 용이하게 취업규칙의 변경이란 형식으로 개별근로자에 대하여 기존 취업규칙에 미달되는 근로계약을 체결할 수 있게 되어 취업규칙의 규범적 효력을 정한 근기법 규정들을 무의미하게 만드는 결과가 되고 또한 한 개의 사업장에 다수의 취업규칙이 병존하는 것과 같은 결과가 되어 취업규칙의 규범으로서의 획일적·통일적 적용의 필요성에도 위배된다고 밝히고 있는데 타당한 해석이라고 고찰된다.

다만, 대법원은 1992년 전원합의체 판결[82]에서 기존 판례를 변경한 이래로 근로자집단의 동의 없이 불이익 변경된 취업규칙에 대해서 기존 근로자에게는 종전의 취업규칙이 신규입사자에게는 변경된 취업규칙이 각각 적용된다는 입장을 계속해서 밝히고 있다.[83][84]

---

80) 대판 1992. 12. 8, 91다38174.
81) 대판 1991. 3. 27, 91다3031.
82) 대법원 1992. 12. 22, 선고 91다45165 전원합의체판결.
83) 앞의 92년 전원합의체 판결의 다수의견은 '근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득 이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어'라고 명시하고 있다. 생각컨대 기득 이익이 침해되지 않는다면 기존 근로자에 대하여도 변경된 취업규칙의 효력이 적용될 수 있다고 볼 수 있겠다: 대판 1997. 8. 26, 96다1726 에서는 '사용자가 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경함에 있어서

2) 취업규칙 변경 후 신규입사자에 대한 적용의 문제

취업규칙의 불이익 변경에 있어서 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 못하여 그 변경이 무효인 경우, 그 변경 후에 채용된 근로자에 대해서 적용될 취업규칙이 무엇인지가 문제로 된다.

이에 대하여 절대적 무효설[85][86]에 의하면 취업규칙의 불이익변경에 있어서 근로자들의 동의를 얻지 못하여 무효라면 종전의 취업규칙이 계속 유효하다고 할 것이고, 종전의 취업규칙이 유효하다면 그 취업규칙의 변경 전에 입사한 사람은 물론 변경 이후에 입사한 사람에 대하여도 종전의 취업규칙이 적용되어야 할 것이지 변경 후에 입사한 사람이라고 하여 무효인 취업규칙을 적용할 수는 없다고 한다.

이에 반하여 상대적 무효설[87][88]은 사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을

근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 아니하였더라도 그 후의 사정변경에 의해 기존 근로자들의 기득의 이익을 침해하지 않게 된 경우, 기존의 근로자들에게 적용될 취업규칙은 개정된 취업규칙이라 할 것이다'라고 판시하고 있다.

84) 92년 전원합의체판결이 나온 후에도 대법원은 불이익변경에 대한 근로자집단의 동의는 집단적의사결정 방식에 의한 동의일 것을 요구하여 간접적으로 같은 취지임을 나타내고 있다: 대판 1993. 1. 15, 92다39778; 대판 1993. 8. 24, 93다16898; 대판 1996. 12. 23, 95다32631; 대판 1997. 7. 11, 97다14934; 대판 1999. 11. 12, 99다30473.

85) 대판 1990. 4. 27, 89다카7754; 대판 1990. 7. 10, 89다카31443; 대판 1991. 12. 10, 91다8777, 8784 병합.

86) 절대적 무효설이란 취업규칙의 변경이 무효라면 모든 근로자에 대해서 그 취업규칙 자체가 무효라는 견해로 법규범설에 입각한 견해로써 취업규칙의 불이익변경에 있어서 근로자들의 동의를 얻지 못하여 무효라면 종전의 취업규칙이 계속 유효하다고 할 것이고, 종전의 취업규칙이 유효하다면 그 취업규칙의 변경전에 입사한 사람은 물론 변경이후에 입사한 사람에 대하여도 종전의 취업규칙이 적용되어야 할 것이지 변경후에 입사한 사람이라고 하여 무효인 취업규칙을 적용할 수는 없다고 한다: 김 형배, 전게서, 212면; 이 병태, 전게서, 952면.

87) 앞의 전원합의체 판결(1992): 취업규칙 변경후에 취업한 근로자에게 적용되는 취업규칙과 기존근로자에게 적용되는 취업규칙이 병존하는 것처럼 보이지만, 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기존근로자에 대한 관계에서 기득이익의 침해로 그 효력이 미치지 않는 범위내에서 종전 취업규칙이 적용될 뿐이므로 하나의 사업내에 둘 이상의 취업규칙을 둔 것과 같이 볼 수는 없다고 한다. 또한 근기법에서는 하나의 사업내에 차등있는 퇴직금제도의 설정을 금하고 있으나, 변경된 취업

근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자들의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득 이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지되지만, 그 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경후의 취업근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다고 한다.

이와 같은 대법원 판례에 대해서는 두 개의 취업규칙 중에서 사용자에 의하여 일방적으로 변경된 취업규칙만이 법규적 효력을 가질 뿐이고 다수의 근로자들이 유지하려고 하는 취업규칙은 법규적 효력을 가질 수 없다는 것은 여전히 법규범설에 부합되지 않는 자의적 합리화 불과하며, 대법원이 종래의 법규범설을 고수하면서 하나의 사업장에서 신규로 채용된 근로자에 대하여 변경된 취업규칙의 유효한 성립을 인정하는 것은 논리의 일관성을 유지할 수 없는 태도로서, 취업규칙의 성질에 대한 계약설의 입장에 따라 기존의 취업규칙과 병존해서 변경된 취업규칙의 유효한 성립을 인정하는 것은 계약자유의 원칙에 합치하는 것이며, 근기법 제97조 제1항 단서에도 위배되지 아니한다고 설명하

규칙의 퇴직금제도가 기존근로자의 기득이익을 침해하는 것이어서 이들에게는 그 효력이 미치지 않고 부득이 종전제도의 적용을 받게 됨으로써 이러한 기득이익이 없는 취업규칙 변경후의 취업근로자에게 적용되는 퇴직금제도와 별개의 퇴직금제도를 적용하는 결과로 되었다고 하여도, 이러한 경우까지 위 법조에서 금하는 차등 있는 퇴직금제도를 설정한 경우에 해당한다고 볼 수는 없다고 한다.

88) 상대적 무효설이란 취업규칙의 변경은 기득권이 침해되는 기존의 근로자에 대해서만 무효이고 신규입사자에 대해서는 유효하다는 견해로 계약설에 입각한 견해이며 사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자들의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지되지만, 그 변경후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고, 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경후의 취업근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다고 한다: 김 형배, 전게서, 212면; 이 병태, 전게서, 952면.

는 견해[89]가 있다.

그러나 앞의 대법원 전원합의체 판결을 계약설의 입장에서 찬성하는 태도에 대해서는 계약설에 근거한 상대적 무효설에 의하면 사용자가 근로자를 신규로 채용할 때마다 일방적으로 취업규칙을 불이익하게 변경하여 신규근로자에게 적용할 수 있게 되어 취업규칙에 대한 법규의 의미를 몰각시키는 결과로 된다는 점, 계약설에 의하면 신규채용자가 변경된 취업규칙에 대해 반대의 의사표시를 하는 경우 그것은 근로계약의 내용으로 되지 아니하며 이러한 경우에는 취업규칙도 근로계약도 존재하지 않는 상태가 된다고 하는 점으로부터의 비판[90]이 있다.

그리고 이와 같은 판례의 견해에 대해서는 취업규칙의 작성·변경에 일정한 절차를 요구한 근기법의 모든 규정은 사용자에 의한 취업규칙의 남용과 오용을 방지하기 위한 강행규정으로 그 절차를 조건으로 취업규칙의 규범성을 인정하였다고 보면 그 절차에 위반한 취업규칙의 변경은 당연히 효력이 없다는 점, 변경절차위반에 따라 취업규칙 변경의 효력이 없다고 보면 신입사원이 동의해야 할 변경된 취업규칙이 없으므로 신입사원의 동의는 성립할 여지가 없다는 점, 신입사원의 동의는 개별적 동의에 불과하므로 근로자집단의 동의를 요구하는 근기법상 동의와는 전혀 다른 개념이라는 점, 근로자집단의 동의가 없는 취업규칙의 불이익변경을 인정할 경우 근로조건을 통일적·획일적으로 처리하려는 취업규칙의 법적 기능을 저해할 우려가 있다는 점 등을 들면서, 상대적 무효설을 내세우는 판례의 입장은 취업규칙의 법적 기능과 성질을 오해하고 근기법 제97조 제1항의 단서의 규정을 곡해한 것으로 보는 견해[91]가 있다.

---

89) 김 형배 교수는 경기의 악화와 같은 기업외적 요인이나 기타 기업내적 사유로 취업규칙의 기준을 하향조정하는 것이 불가피한 경우에는 변경된 취업규칙의 내용이 기존의 것에 비하여 불리하더라도 기득이익의 침해라는 문제가 발생하지 않는 신규채용 근로자에 대해서 변경된 취업규칙을 적용할 수 있다고 보아야 한다라고 밝히고 있으면서 결과적으로 위 대법원 판결은 취업규칙의 법적 성질을 파악함에 있어서 계약설을 수용하는 태도라고 한다: 김 형배, 전게서, 214면 이하.

90) 박 홍규, 전게서, 354면.

91) 이 병태, 전게서, 953면.

생각컨대 취업규칙의 불이익 변경에 있어서 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 못하여 그 변경이 무효인 경우, 그 변경 후에 채용된 근로자에 대해서 적용될 취업규칙에 대한 대법원의 전원합의체의 판결내용을 보면, 취업규칙을 규범설의 입장에서 파악하는 대법원의 기본입장과 달리 계약설적인 입장에서 접근하고 있다는 점은 부인 할 수 없다. 이는 법규범설과 계약설의 경직적인 처리기준에 대신하여 근로자의 기득 이익을 보호하면서도 기업경영상의 필요성도 고려한 구체적인 처리를 도모한 귀결이라고 생각된다.

3) 변경 후 유리하게 된 경우

취업규칙의 변경이 불리한 변경인지를 판단하는 기준시점은 취업규칙 변경이 이루어진 시점으로 되는데, 불이익변경 후 사정변경에 의해 유리하게 된 경우에 대해 대법원 1997, 8, 26 96다1726 판결은 사용자가 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경함에 있어서 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻지 아니하였다고 하더라도, 취업규칙의 작성·변경권이 사용자에게 있는 이상 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기득이익이 침해되는 기존 근로자에 대하여는 종전의 취업규칙이 적용될 따름이므로, 취업규칙의 개정이 그 개정 당시에는 근로자들에게 불리하였어도 그 후의 사정변경에 의하여 기존 근로자들의 기득의 이익을 침해하지 않게 된 경우에는 그 개정에 대한 근로자들의 동의가 없었더라도 기존의 근로자들에게 적용될 취업규칙은 개정된 취업규칙이라고 하고 있다.

앞의 사례의 경우 퇴직금 규정의 개정 당시 사정만을 기준으로 개정전의 규정에 의한 퇴직금과 개정후의 규정에 의한 퇴직금을 산출하여 비교하면, 이 규정의 개정은 단기근속자들에게는 유리하나 장기근속자들에게 불리하여 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 얻었어야 하는데[92] 그 동의를 얻

지 못하여 무효인 취업규칙 개정이었다.

그런데 이 개정 이후에 수당들이 신설되어 퇴직금 산정의 기초임금에 포함됨으로써 당해 사건 원고들의 경우 개정전의 퇴직금규정에 의하여 산정된 퇴직금액보다 개정후의 퇴직금규정에 의하여 선정된 퇴직금액이 더 크게 되어 결국 개정후의 퇴직금규정에 의하더라도 원고들의 기득의 이익을 침해하지 않게 되었다고 보아 원고들에게는 개정된 퇴직금규정을 적용하여야 한다고 결론을 내린 것으로 보여진다.

이와 같은 판례의 입장을 취할 경우 규정 개정이후 퇴직시점에 따라 적용되는 규정이 달라지게 되는데, 이는 취업규칙의 법적 성질에 대해 기본적으로 법규범설적인 입장을 취하면서도 근로자의 기득의 이익과 근로조건의 집합적 처리 필요성과 기업경영의 탄력성 등을 구체적 상황에 조화시켜 계약설적인 면을 부분적으로 인정할 결과라고 보여진다.

제4절 취업규칙의 불이익변경의 구체적 판단기준

사용자에 의한 취업규칙의 불이익변경은 변경전과 변경후의 근로조건을 살펴보면 그것이 불이익한 변경인지를 판단할 수 있을 것이다. 예를 들면 정년제의 신설, 퇴직금의 감액, 임금의 감액, 근로시간의 연장, 휴가부여방식의 변경, 근무형태의 변경 등이 있다.

이러한 내용의 취업규칙의 불이익변경에 대한 판단은 용이하게 할 수 있지만, 문제가 되는 것은 변경된 취업규칙이 일부분은 유리하게 변경되었지만, 다른 일부분은 불리하게 변경된 경우에 불이익변경에 대한 판단이 어렵다는 것

92) 앞에서 살펴 본 바와 같이 판례법리에 따르면 취업규칙의 개정에 의하여 근로자 상호간의 이익·불이익이 충돌되는 경우에는 전체적으로 불이익한 것으로 취급하여, 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하도록 하고 있다: 대판 1993. 5. 14, 93다1983; 대판 1995. 3. 10, 94다18072.

에 있다.

예를 들면 퇴직금의 지급율을 하향조정하면서 퇴직금 산정의 기초인 평균임금의 산정방식을 근로자에게 유리하게 변경하는 경우, 기본급을 인하하면서 상여급을 인상하는 경우와 같이 동일유형 내에서 근로자에게 유리한 변경과 불리한 변경이 동시에 행하여 질 수 있으며, 퇴직금의 지급율을 저하시키면서 상여금의 지급율을 상승시켰을 경우와 같이 동일한 변경시 근로자에게 이익되는 부분과 불이익한 부분이 공존하지만 각 부분이 서로 다른 유형에 속하는 경우도 존재한다.

1. 임금에 관한 구체적 판단

1) 불이익 판단기준

임금체계의 개편과 관련하여 취업규칙의 불이익변경에 해당하는지 여부에 대하여는 일반적으로 개편 후 임금총액이 종전보다 적다면 불이익변경에 해당하게 될 것이다.

대법원 판례[93]에 따르면 사단법인이 구 급여규정 및 사무국직원수당 지급방침 등에 의거하여 매월 출퇴근교통비와 직무수당 및 장기근속수당을 지급하여 오다가 직원들의 의사도 묻지 아니한 채 일방적으로 위 급여규정들을 개정하여 위 출퇴근교통비, 직무수당, 장기근속수당을 폐지하고 새로이 학자보조금수당과 가족수당을 신설하는 한편 승급제도를 개정하고 각 지급간의 급여차액을 확대함으로써 일정기간에 있어서 직원들이 위 개정 급여규정에 의하여 수령한 임금총액이 종전 급여방식에 의하여 산출된 임금총액보다 적다면 위 개정급여규정은 종전 급여규정 등의 적용을 맞고 있던 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의 없이 근로자에게 일방적으로 불이익하게 변경된 것이어서 취업규칙변경으로서의 효력을 지닐 수 없다고 하고 있다.

---

93) 대판 1992. 4. 10, 91다37522.

그런데 이와 같은 임금체계 개편에 있어서 특정근로자집단에 대하여 불이익하게 변경되어진다면 근로자 전체에 대하여 유리한 변경에 해당할지라도 취업규칙 불이익변경에 해당되는 것이기 때문에 근로자집단의 동의를 요하는 것으로 해석하는 것이 타당할 것으로 보여진다. 그리고 이에 관하여는 이후에 자세히 언급하도록 하겠다.[94]

이와 같은 해석은 대법원 판례에서도 보여지는바 이 판례[95]에 따르면 취업규칙의 일부를 이루는 급여규정의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 그러한 변경에 근로자집단의 동의를 요하는지를 판단하는 것은 근로자 전체에 대하여 획일적으로 결정되어야 할 것이고, 또 이러한 경우 취업규칙의 변경이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지 객관적으로 평가하기가 어려우며 같은 개정에 의하여 근로자 상호간의 이익·불이익에 따른 이익이 충돌되는 경우에는 그러한 개정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급하여 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다고 한다.

한편 임금이란 기본급(고정급과 능률급을 포함)외에 수당, 상여금 등을 모두 포함하는 개념으로서 그 자체가 하나의 영역을 형성하고 퇴직금, 근로시간 등과 함께 근로조건의 중요한 요소로 되어 있다. 즉 임금을 증액시킴과 동시에 퇴직금의 지급기준을 저하시키거나 근로시간을 연장하는 경우에는 양자가 상호보완 할 수 없는 영역의 것이므로 임금의 증액분이 월등히 높다고 할지라도 실질적으로 근로자에게 불이익한 부분이 항상 존재하기 마련이다. 또한 임금의 영역안에 있는 기본급, 상여금, 수당 등의 변경은 당연히 상호 보완할 수 있는 관계에 있는 기간을 정하여 그 기간동안 근로자가 수령할 수 있는 임금의 총액을 산정 한 후 변경전과 변경후의 임금을 비교함으로써 그 불이익을 판단하여야 할 것으로 보여진다.[96]

---

94) 이것은 결국 유리의 원칙을 적용하느냐의 문제로서 후술하는 제4장 이하에서 자세히 살펴보기로 한다.

95) 대판 1993. 5. 14, 93다1893.

쟁의행위와 관련하여 쟁의행위 또는 조합활동으로 인하여 근로를 제공하지 않는 경우 가족수당 등을 공제대상으로 한다는 취지의 취업규칙의 변경을 불이익하다고 볼 것인지는 무노동·무임금 원칙을 살펴봄으로서 고찰하여보면 될 것으로 보여진다.

판례[97]및 임금이분설[98]에 입각하여 쟁의행위 등으로 인하여 근로를 제공하지 아니한 경우에도 생활보장적 임금은 지급해야 하는 것으로 본다면, 가족수당을 생활보장적 임금이라고 판단하는 한 그것은 불이익한 변경이 된다. 물론 임금이분설에 의하더라도 교환적 임금에 해당하는 부분을 공제대상으로 하는 것은 법리상 당연한 것이므로 이를 불이익이라 판단할 수 없음은 당연하다 하겠다.[99]

---

96) 일본에서는 임금체계하에서 개개의 급여 및 수당은 전체의 일부분에 지나지 않는 것이므로 승무원 임금규정의 변경도 불가분한 일체의 것으로 되어진 것이 명백하다. 따라서 이것에 포함된 개개의 급여 및 수당자체가 불이익하게 변경되었는지 여부를 비교하여도 아무런 의미가 없으므로 승무원이 지급을 받고 있는 급여, 각종 수당의 총액으로써 비교할 수 밖에 없다라고 판시한 예가 있다: 高圓寺交通事件, 東京地裁, 1990. 6. 5 勞働判例大系 14, 勞働旬報社, 381면.

97) 대판 1992. 3. 27, 91다36307.

98) 임금이분설이란 임금은 근로제공의 대가로 지급되는 임금과 근로제공과는 무관하게 종업원이라는 지위를 취득함에 따라 지불되는 임금으로 나누어지고, 후자의 임금은 근로자의 생활보조적인 성질을 지니므로 파업·지각·조퇴 등과는 무관하게 지급되어야 한다는 것을 말하는 것으로 종래 우리 나라의 판례(대판 1992. 3. 27, 91다 36307; 대판 1992. 6. 23, 92다 11466)도 임금이분설의 입장을 취하고 있었다. 이후 전원합의체판결(1995. 12. 21, 94다 26721)에서 '우리의 근기법 등 현행법률들이 임금을 근로의대가로 파악하고 있으며, 우리 판례의 일관된 태도임에 비추어 볼 때, 모든 임금은 근로의대가로서 현실의 근로제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생한다는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없을 뿐만 아니라, 그와 같이 임금을 이분할 아무런 법적 근거가 없다'라고 판시하여 임금이분설을 폐기하였다; 이와 같은 취지로 김 형배 교수는 근로계약의 본질은 어디까지나 근로자의 노무급부의무와 사용자의 임금지급의무가 대가적인 쌍무관계에 서는 것으로 이해해야 한다라고 하며 근로자의 노무제공을 전제로 하지 않는 사용자의 생활보장적 임금지급의무를 인정하는 임금이분설은 근로의 대가를 지급 내지 산정하는 방법과 근거를 혼동하고 있는 것이다라고 하였다: 김 형배, 전게서, 241면.

99) シェル石油・シェル化學事件, 東京地裁 1979. 10. 12, 勞働判例大系, 勞働旬報社, 378면: 가족수당을 본급·주택수당과 함께 기본임금의 하나로서 지급한다는 취지의 급여규정을 개정함과 아울러 쟁의·조합활동 등으로 인한 무노동 공제의 대상으로 규정한 것은 합리적인 근거가 있고, 또한 신규정의 내용도 합리적인 것이라고 인정되며, 그 외 종업원의 기득의 이익을 침해하였다고 평가할 수도 없다라고 하여 불이익이 아니라는 취지

2) 연봉제 도입의 경우

임금체계의 개편과 관련하여 연봉제의 도입이 취업규칙 불이익변경에 해당하는지 여부가 문제될 수 있다. 연봉제라 함은 근로에 대한 보수를 연단위의 총액으로 설정하는 임금제도로서 시간급, 일급, 주급의 여러 제도에 대응하는 용어라고 할 수 있다.[100]

그러나 우리 나라와 일본에서 주로 보급되고 있는 연봉제는 변형된 형태로서 기본연봉을 확정액으로 하는 형태로 고정급으로 하면서 업적연봉[101]에 전년도의 평가를 반영케 하여 변동부분으로 하는 타입을 취하고 있다.

이러한 경우의 연봉제는 임금의 지급형태와 고용기간을 직결시키지 아니하고, 고용의 쪽은 기간의 정함이 없는 계약으로서 계속케 하면서 임금을 연봉제로서 연간급여로 하는 형태를 취하는 것에 의해 연봉액의 변동폭도 업적연봉으로서 비교적 소폭으로 억제된다고 한다.[102]

이와 같은 연봉제를 도입하려고 하는 경우 임금형태 변화에 대한 위 판례법리를 참조한다면, 그 도입을 전후하여 대상근로자의 임금수준이 떨어진다든가 작업강도가 강화된다 하는 경우에는 취업규칙이 불이익하게 변경된 것이라고 보아야 할 것으로 보여진다.

그리고 연봉제를 근로자들 일부에 대하여 도입하려고 하는 경우에는 연봉제 근로자는 기업내에서 하나의 부분사회를 구성하는 존재이고 부분사회를 구성

로 판시하고 있다.

100) 김 재훈, 위의 논문, 151면.

101) 업적 연봉은 상여금의 형태를 취하는 경우가 많다고 한다: 김 재훈, 위의 논문, 151면.

102) 연봉제의 원래의 모습은 고용기간을 유기고용으로 하면서 연봉도 고정부분과 변동부분으로 나누지 않고 전체를 변동의 대상으로 하는 타입이기 때문에 이와 같이 변형된 형태의 연봉제는 고용과 임금의 안정을 보다 중시한 제도라고 할 수 있으며 연봉제에 있어서 공정한 평가의 문제, 임금에 대한 개별교섭의 문제, 고충처리문제 등이 생길 수 있는데 이에 대해서는 土田道夫, 能力主義 賃金と勞働契約, 季刊勞働法 제185호, 1998, 17-19면; 김 소영, 연봉제 실시에 관한 법적 검토, 연봉제 어떻게 할 것인가, 한국노동연구원・한국경제신문사, 1998, 3면 참조.

하는 법규범의 작성·변경에는 부분사회 구성원 자체가 직접 참가하는 길이 보장되어야 하기 때문에 그 적용대상자 과반수의 의견을 듣거나 동의를 얻어야 할 것[103]이다.

2. 퇴직금에 관한 구체적 판단

1) 단체협약에 의한 불이익변경의 동의

단체협약에 의한 불이익변경의 동의는 앞서 취업규칙의 효력부분에서 언급한 것과 마찬가지로 대법원 판례중에는 단체협약에 의한 불이익변경의 동의를 인정하고 있는 판례가 있다.[104]

그리고 이에 대한 문제점들을 검토하였는바[105] 퇴직금규정과 관련하여 취업규칙상 퇴직금지급률을 인하함에 있어서 근로자의 집단적 동의 없이 행하여 무효이었는데 이후 단체협약에 의하여 소급적으로 동의한 경우 이에 대한 퇴직금규정의 불이익의 판단에 있어 문제가 됨은 앞서 언급한 바와 같다.

앞의 대법원 판결을 살펴보면 근로자의 집단적 동의 없이 불이익 변경된 취업규칙 규정에 대하여 단체협약에 의하여 소급적 동의를 할 수 있다고 하면서 퇴직금지급률에 대한 불이익변경의 소급적 동의를 인정하고 있다. 그러나 이러한 단체협약의 사후 동의에 의한 퇴직금의 불이익변경에는 다음과 같은 문제점이 있다고 보여진다.

즉, 퇴직금청구권을 불확정기한부채권이라고 본다면 민법의 규정(민법 제154조에 의한 148조의 준용으로 기한 있는 법률행위의 당사자는 기한의 성부로 인하여 생길 상대방의 권리를 해하지 못한다)에 의하여 당해 근로자의 동

---

103) 오 문완, 임금형태의 변화의 법적 문제, 산업관계연구 제6권, 한국노사관계학회, 1996, 207-208면.

104) 대판 1992. 8. 22, 96다6967; 대판 1992. 11. 24, 91다31753; 대판 1997. 8. 22, 96다6967.

105) 위 논문, 제3장 제3절 취업규칙 변경의 효력상의 문제점.

의나 다른 특별한 사정이 없는 한 근로자의 구체적 기득권을 침해할 수 없다고 할 수 있을 것이다.

퇴직금의 법적 성격이 후불임금[106]이라고 한다면 근로자는 근속연수에 달함에 의하여 당해 근속연수에 대응하는 일정한 퇴직금지급청구권을 취득하게 된다는 것을 의미하고, '이미 성립한 개인의 청구권'에 해당하며 그 시점마다 근로자의 사적 재산영역으로 이행하는 채권에 상당한 것으로 고찰할 수 있다고 한다.[107]

그러나 대법원 판례[108]는 퇴직금 채권의 발생시기에 대하여 근로계약이 존속하는 한 사업주의 퇴직금 지급의무는 발생할 여지가 없고 근로계약이 종료하는 때에 비로소 그 지급의무가 생긴다고 하여 퇴직 전에는 퇴직금 채권이 발생하지 않는 것으로 보고 있으나 타당한 해석인지는 의문이다.

2) 불이익 판단기준

취업규칙의 불이익변경에 관한 지금까지 대법원 판결의 대부분이 퇴직금규정에 관한 것[109]이다. 그리고 일반적으로 퇴직금규정의 변경을 전후하여 금액의 변동이 있는 경우에는 그 액수를 비교하여 불이익변경인지 여부를 판단할 수 있을 것이다. 즉 근로자들의 동의 없이 개정된 퇴직금규정이 개정 전 그것보다 퇴직금지급일수의 계산 및 퇴직금산정의 기초임금 범위내에 있어서 근로자들에게 불리하게 변경된 것은 무효[110]이다.

---

106) 퇴직금의 법적 성격에 관하여 생활보장설・공로보상설・임금후불설 등이 있으나 현재 우리 나라의 통설은 임금후불설이며 판례도 같은 견해를 밝히고 있다: 김 형배, 전게서, 299-300; 임 종률, 전게서, 373-374면.

107) 渡邊章, 協約自治と個別勞働者の法的地位, 日本勞働法學會誌, 제38호, 1971, 66면 이하에서는 퇴직금이 후불임금이라고 하는 의미를 정지조건부 내지 기한부채권으로 이해하지 아니하고, 사용자가 퇴직시까지 지급일의 항변권을 갖는 것으로 해석하고 있다.

108) 대판 1991. 6. 28, 90다14560.

109) 대판 1993. 2. 9, 91다21381; 대판 1993. 10. 12, 93다18365; 대판 1996. 9. 10, 95다15414; 대판 1996. 12. 23, 95다32631; 대판 1999. 8. 20, 98다765.

110) 대판 1991. 6. 28, 90다15952, 15969, 15976.

대법원 1997. 8. 26, 96다1726 판결은 회사가 보수규정에서 새로운 수당을 지급하도록 규정함과 동시에 새로이 지급되는 그 수당을 퇴직금 산정의 기초임금에서 제외시킨 경우에는 퇴직금규정의 개정을 전후하여 퇴직금액수에 변동이 있는 것이 아니어서 기존의 근로자들의 기득의 권리나 이익을 박탈하는 것이 아니므로 이와 같은 개정은 근로자에게 불리한 개정이라고 할 수 없다고 한다.

또한 퇴직금의 산정기준이 근기법과 달라도 그 산정된 금액이 법상의 하한선을 상회하는 경우에 대해 대법원 1992. 6. 9, 92다6716 판결은 근기법상 퇴직금은 사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급할 퇴직금액의 하한선을 규정한 것으로 보아야 하므로 회사측이 그 보수규정에 의하여 산출한 퇴직금산정의 기준이 되는 각 수당액이 근기법 규정을 적용하여 산출한 각 수당액에 미달된다 하더라도 퇴직급여 지급률을 단수제가 아닌 누진제로 규정한 결과, 산정된 근로자에 대한 퇴직금액이 근기법이 보장한 하한선을 상회하는 금액이라면 이러한 보수규정은 근기법에 저촉되는 위법한 규정이라고 볼 수 없다고 한다.

3. 근로시간에 관한 구체적 판단

1) 불이익판단의 기준

근로시간의 변경이 근로조건의 불이익변경에 해당하는지는 우선, 변경 전후의 근로시간을 계산함으로써 쉽게 알 수 있다. 그러나 법정근로시간의 단축으로 인하여 임금이 감소될 수 있는가 하는 점이 문제로 될 수 있으며[111] 근로

111) 이에 대하여 ILO 제116호 권고 제4조에서는 명문으로 근로시간 단축시 임금이 조금도 감소됨이 없이 점진적으로 감소되어야 한다고 밝히고 있으며 아울러 이 권고 제8조에서는 정규근로시간의 점진적 단축의 방식으로 시간적 간격을 두는 단계적 방식, 국민경제의 각부문과 분야로 점진적으로 확대시키는 단계적 방식, 이러한 두 가지 방식의 결합, 기타 국내상황과 각 경제활동의 조건에 가장 적절한 다른 방식을 제시하고 있다.

시간이 늘어남에 있어 임금의 증액이 따르기 마련이므로 이에 대한 근로자들의 이익·불이익 여부를 판단하기란 어려움이 있다.[112]

근로시간의 감소에 따른 임금의 감소와 관련하여 ILO 제47호 협약 제1조에서는 생활수준의 저하를 초래하지 아니하는 방법으로 적용되는 주40시간제의 원칙을 선언하고 있다. 이와 같이 ILO 협약을 참조한다면 법정근로시간의 단축은 근로자의 생활의 질을 향상시키는데 그 목적이 있다고 할 수 있을 것이고, 이 경우 단축된 근로시간만큼 임금을 삭감하는 규정은 취업규칙의 불이익변경에 해당한다고 한다.[113]

근로시간의 증가에 따른 임금의 증액에 있어서 근로시간의 증가라는 불이익부분과 임금의 증액이라는 이익부분의 비교형량을 통하여 이익된 부분이 많다면 불이익변경은 아닐 것(마찬가지로 근로시간이 감소함과 동시에 임금이 감소하는 경우에도)[114]이나, 이러한 비교형량에 있어서 근로자와 사용자사이의 합의가 없는 경우(대개 근로자들이 이러한 비교형량을 불이익하다고 판단하는 경우) 근기법 제97조 제1항의 단서의 규정이 아닌 '합리성'이론에 의하여 취업규칙을 변경한다면 이러한 이유로 인하여 근로자 집단의 동의에 대한 회피수단 및 상기의 비교형량을 함에 있어서 법관의 자의가 개입될 소지가 발생할 수 있다는 문제점이 있다.

2) 탄력적 근로시간제의 도입의 경우

근기법 제50조 제1항에서는 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 취업규칙이 정하는 바에 의하여 시행할 수 있도록 하고 있다. 즉 사용자는 취업규칙에서 정하는 바에 의하여 2주간 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 44시간을 초과하지 아니하는 범위안에서 특정주에 44시간을, 특정일에 8

112) 왜냐하면 이익되는 부분과 불이익되는 부분이 서로 다른 근로조건의 유형에 속하기 때문이다.
113) 김 재훈, 위의 논문, 164면.
114) 대판 1984. 11. 13, 84다카414.

시간을 초과하여 근로하게 할 수 있으나 특정주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

이러한 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 실시함에 있어서 취업규칙의 변경이 수반되어야 한다. 문제는 그 취업규칙의 변경이 불이익변경에 해당하여 근로자의 집단적 동의를 요하는가에 있다. 탄력적 근로시간제의 채택으로 특정주 또는 특정주 또는 특정일에 법정근로시간을 초과하는 부분에 대하여 연장근로수당을 지급 받지 못하는 불이익이 있기 때문에 취업규칙의 불이익변경에 해당한다고 보는 견해[115]가 있다. 그리고 탄력적 근로시간제는 근로시간을 고르게 배분하지 않고 근로자의 생활을 불규칙하게 만들기 때문에 이 제도를 도입하는 취업규칙은 불이익변경에 해당되고 따라서 근로자의 집단적 동의를 요한다고 보는 견해도 있다.[116]또한 탄력적 근로시간제의 운용은 제3차 산업의 발전과 경제의 용역화·유연화에 따라 계절별·월별 또는 요일별로 업무량의 증폭이 크므로 이에 대응하여 근로시간을 탄력적으로 배치함으로써 효율적인 인적관리를 가능케 하려는데 그 취지가 있으나 그 폐단도 적지 않다고 한다.[117]

그러나 2주 단위의 탄력적 근로시간제는 일반적으로 근로시간 변동의 폭이 크지 않다는 점, 근로시간이 특정 근로일에 집중되는 만큼 휴일이 증가하는 이익도 수반되는 점, 이러한 점들을 고려하여 입법자가 근로자대표와의 서면합의가 아니라 취업규칙에 의하여 할 수 있도록 한 점 등을 종합하여 보면 2주 단위의 탄력적 근로시간제로 근무형태를 변경하는 것이 반드시 취업규칙의

115) 탄력적 근로시간의 채택은 사용자에게 있어서 생산성향상은 물론 시간외근로수당의 절감효과를 가져오는 반면에 근로자에게는 여가 선용의 기회가 확대된다고 하지만, 이를 반드시 시간외근로수당의 지급이 이루어지지 않은 것에 대한 대가적 이익으로 볼 수는 없으므로 결국 근로자의 경우에는 불이익한 변경에 해당된다고 볼 수 있으므로 이 경우에는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다고 한다: 김 형배, 전게서, 328면.

116) 이 병태, 전게서, 813면.

117) 이 병태 교수는 이와 관련하여 외국의 경우를 소개하면서 첫째 노동조합을 비롯한 근로자대표의 동의가 있고 그 기간은 1년 이내일 것, 둘째 주 40시간의 기준시간 범위 내에서만 변칙이 인정될 것, 셋째 특정한 주 또는 특정한 날의 근로시간을 명백히 정하고 주 60시간, 1일 12시간을 초과하지 않을 것 등의 엄격한 요건을 전제로 탄력적 근로시간제를 인정하고 있다고 한다: 이 병태, 전게서, 813면.

불이익변경이라고 단정할 수는 없다고 한다.[118]

생각컨데 탄력적 근로시간제의 입법취지를 고려하여 취업규칙의 변경시에 탄력적 근로시간제의 적용에 있어서 그것이 불이익변경인지의 여부는 객관적·종합적으로 판단하여야 할 것으로 보여진다. 즉, 탄력적 근로시간제의 도입이 바로 취업규칙의 불이익변경에 해당되지 않는다는 것이다.

4. 정년제에 대한 구체적 판단

1) 정년제의 신설의 경우

애초에 취업규칙상에 정년제에 대한 규정이 없다가 정년제[119]를 취업규칙의 개정을 통하여 새로 도입한 경우 이를 어떻게 볼 것인가가 문제가 될 수 있다.[120][121]

정년제 신설에 대하여 대법원 1978. 9. 12, 78다1046 판결은 정년을 55세로 하는 규정의 신설에 대해 이와 같은 정함이 사회의 일반통례에서 벗어난 불합리한 제도라고 볼 수 없으므로 이러한 정년제의 신설이 근로자의 기존 근로조건상의 기득권을 침해하는 근로조건변경이 아니라고 하였다.[122]

---

118) 임 종률, 전게서, 395면.

119) 정년제라함은 취업규칙 또는 근로계약에서 정한 일정한 연령에 도달하면 근로자의 근로계속의 의사 및 능력 여하에 불구하고 근로계약관계를 종료시키는 제도이다: 김 형배, 전게서, 480면; 임 종률, 전게서, 513면; 秋田·青木宗也, 勞働基準法講義, 107면.

120) 정년제의 목적으로는 근로자로 하여금 기업에 대한 귀속의식을 갖게 하고, 근로자의 신분보장을 꾀한다는 점에서 고용안정을 도모할 수 있으며 또한 노령화된 노동력을 배제시키는 기능을 가짐으로써 기업의 합리적·능률적 운영을 돕게 할 수 있다고 한다: 김 형배, 전게서, 480-481면.

121) 그러나 정년제의 위와 같은 목적에도 불구하고 우리 기업에서 보편화되어 있는 55세를 전후한 정년제는 국민들의 평균수명과 노동가능연령의 대폭적인 신장, 고령자의 생활환경의 변화와 고령자의 정년 후의 재취업이 용이하지 않은 실정 등에 따라 고령자의 생활에 커다란 위협이 되고 있다. 이러한 문제점은 우리 나라가 현재 빠른 속도로 고령화사회로 나아가고 있는 현실에 비추어 볼 때 매우 심각한 것이라 할 수 있으며 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 고령자고용촉진법이 제정되었다.

이후 대법원 1997. 5. 16, 96다2507판결은 운수회사 근로자들에 대하여 만 55세의 정년제 규정을 신설하고 회사심사에 의하여 일정한 경우에만 만 55세를 넘어 근무할 수 있도록 한 것은 근로자집단의 동의를 얻지 않아도 될 사회적 합리성이 있다고 할 수 없고, 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하는 불이익한 근로조건 변경에 해당한다고 밝히고 있다.

그런데 이 사안에서 정년제 신설에 대하여 노사협의회에서 노동조합 위원장을 포함한 근로자위원 전원의 동의를 얻어서 이를 취업규칙의 불이익변경에 필요한 동의로 볼 수 있는지가 문제로 되었는데, 위 대법원 판결은 노동조합의 동의는 법령이나 단체협약 또는 노동조합의 규약 등에 의하여 조합장의 대표권이 제한되었다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 조합장이 노동조합을 대표하여 하면 된다고 하여 노동조합 위원장이 위 정년규정의 신설에 이의가 없다는 취지의 의견을 제시하였다면 근로자에게 불이익한 취업규칙의 신설 등에 대한 노동조합 위원장의 동의권이 제한되어 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그것은 적법한 노동조합의 동의라고 보아야 한다고 밝히고 있다.

그러나 노사협의회는 노사공동의 이익을 증진함으로써 산업평화를 도모할 것을 목적으로 하는 제도로서, 노·사 사이의 이해의 대립을 노동조합의 단결과 쟁의행위를 통해서 근로자들의 실질적 평등을 유지하기 위하여 마련된 단체교섭제도와는 그 취지를 달리 하는 제도이므로, 근로조건의 결정은 단체협약의 대상에 포함되는 것으로 일반적으로 노사협의회가 합의대상으로 할 수 없는 것이라고 보아야 할 것[123]이다. 그리고 위 노사협의회에서 합의가 가령 단체협약으로서 그 효력을 인정할 여지가 있을 수 있는데, 이와 같은 근로조건의 불이익변경은 근로자의 이해관계에 중요한 영향을 미치게 되므로 당해

---

122) 이 판례는 당시가 1970년대였다는 시대적 상황을 감안하더라도 근로자들의 근로기준을 정하는 취업규칙의 불이익변경이 쉽사리 인정되어서는 아니 될 것이며, 사회적 상당성이라는 원칙에 의하여 취업규칙의 불이익변경에 대해 근기법상 절차를 무시하고 그 효력을 인정해서는 아니 될 것으로 보여진다.

123) 대판 1994. 6. 14, 92다28556에서 비록 회사가 근로조건에 관한 사항을 노사협의회의 협의사항으로 규정하고 있더라도 근로자들이 노사협의회를 구성하는 근로자위원들을 선출할 때 그들에게 근로조건을 불이익하게 변경함에 있어서 근로자들을 대신하여 동의를 할 권한까지 포괄적으로 위임한 것으로 볼 수 없다고 판단하고 있다.

불이익변경이 협약목적의 관점으로부터 정당하다고 허용되기 위해서는 특히 노동조합 내부에 있어서의 단결의사의 형성절차가 중요한 의의를 지니게 된다고 볼 때, 불이익한 근로조건의 변경에 대해서 별다른 성찰 없이 일반적인 근로조건의 변경의 경우처럼 그 효력을 인정하려고 하는 위 대법원 판례의 입장에는 비판의 여지가 많다고 할 것[124]이다.

생각컨데 정년제에 관하여 정년제의 규정이 없다면 근로자들은 제한 없이 계속 근무할 수 있다는 기대를 지닐 수 있고 이는 근로자가 지니는 기득의 권리나 이익에 해당한다고 할 것이므로 정년제 규정의 신설은 취업규칙의 불이익변경에 해당되는 것이라고 볼 수 있을 것이다. 그러므로 이와 같은 변경은 근로자 개인의 지위에 관계되는 중요한 문제이고 원칙적으로 근로자의 집단적 동의에 따라 결정되어야 할 사항으로 보여진다.

그리고 근로자들이 이에 대한 규정 신설에 대하여 동의하거나 또는 노동조합에 대하여 특별한 수권을 부여하여야 그 신설의 효력이 인정될 수 있을 것으로 보여진다. 다만 위 판례에서 언급한 바와 같이 노사협의회에서 노동조합 위원장의 동의가 노동조합에 의한 동의가 될 수 있는지는 의문이다.

2) 정년의 단축의 경우

기존의 취업규칙상의 정년을 단축하는 취업규칙의 변경은 정년제의 신설의 경우와는 달리 일반적으로 불이익하다고 봄이 타당하다. 왜냐하면 정년제 자체가 존재하지 않았을 경우에는 단지 연령에 관계없이 일할 수 있는 가능성이

124) 취업규칙의 불이익변경은 사용자가 일방적으로 하는 것으로서 근로자들에게는 기존의 근로조건을 후퇴시키는 것이어서 본 건과 같이 노동조합장 개인의 의견서로 대치하게 한다면 매우 불합리한 결과가 발생할 수 있으므로 노동조합과 사용자간의 역동적인 관계를 규율하는 노조법상 대표자의 협약체결권한에 관한 견해를 최저의 근로조건을 규정함으로써 개별근로자를 보호하고자 하는 근기법상의 취업규칙 불이익변경에 관한 본 사례를 원용할 수 없다고 하는 점에서 비판하는 견해가 있다: 김 남준, 정년규정 신설이 취업규칙의 불이익변경에 해당하는 여부와 노동조합의 동의의 효력, 1997년 노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회 편저, 1998, 275-277면 참조.

근로자에게 존재할 뿐이지만, 이미 정년제가 정하여져 있다면 그 가능성이 현실로 구체화한 것이므로(정년제의 신설로서 근로자에게 불이익부분이 된 것) 이를 단축하는 것은 근로자들에게 신설의 경우보다 더욱 불이익을 주는 것이기 때문이다.

대법원은 1994. 5. 13, 93다47790 판결을 통하여 사용자가 정년연령을 낮추어 취업규칙을 규정하는 경우에는 근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하는 것이므로 종전 취업규칙의 적용을 받던 근로자집단의 집단의사 결정방법에 의한 동의를 요한다고 밝히고 있다.

이에 기존의 취업규칙을 적용 받고 있는 근로자에 대하여 정년연령의 인하는 근로조건의 불이익한 변경이며 따라서 이에 대한 취업규칙의 규정이 효력을 가지려면 근로자집단의 집단적 동의를 얻지 아니하면 안될 것이다.

아울러 근로자가 이미 확보하고 있는 근로계약상의 지위를 사용자가 취업규칙에 의하여 일방적으로 변경할 수는 없는 것이므로, 근로자의 동의를 얻지 못하는 이상 변경된 정년연령에 달하여도 해당 근로자의 근로관계는 자동적으로 종료되지 않는다고 한다.[125] 그리고 정년제의 단축에 관하여 대부분의 일본판례는 불이익이라는 전제하에 그 효력여부를 판단하고 있다.[126]

제5절 기업변동시 취업규칙의 변경에 관한 문제점

1. 문제제기

기업의 변동은 일반적으로 기업의 상황이 어려운 경우에 나타나므로 근로자

125) 蓼沼謙一, 停年, 勞働法實務大系 5권, 208면.
126) 勞働判例大系14, 402-404면.

들은 계속적인 근로관계의 유지가 어려우며 비록 근로관계가 유지된다고 할지라도 기업변동 이후 근로관계의 내용에 관하여 근로조건이 하향된다면 이는 결과적으로 근로자의 생존권보장을 이념으로 하는 근기법 정신에 부합하지 못하는 것이 된다.

기업의 변동은 경영사정악화로 인한 것과 기업간의 전략적 제휴차원에서 이루어진다고 볼 수 있다. 다만 기업의 변동시에 나타나는 제반사항들 중에 취업규칙의 변경이 수반하게 된다는 특징이 있다.

위와 같은 특징을 가진 기업의 변동은 합병[127]이나 영업양도[128] 등의 형태로 이루어지는데, 합병에 대한 합의서 또는 영업양도에 대한 계약서 등을 통하여 취업규칙의 변경 문제를 해결하는 것이 보통이다. 그러나 그러한 합의가 존재하지 않는 한 합병이나 영업양도 후에 취업규칙의 변경이 된 경우에는 통상적인 취업규칙의 변경의 경우와 다르게 볼 필요성이 있다. 다만 합병의 경우에는 소멸회사의 권리의무관계가 일괄하여 합병회사에 포괄승계 되므로 소멸회사와 근로자간의 근로계약 내지 노동관계도 당연히 합병회사에 승계 되지만[129] 영업양도의 경우에는 양도인과 근로자간의 노동관계가 당연히 양수인에게 승계되는지에 관하여는 견해의 대립이 있다.

2. 근로관계의 승계여부

기업의 변동시(영업양도의 경우)에 취업규칙의 규율을 받던 근로관계가 어떻게 되느냐의 문제에 관하여는 학설이 나뉜다.

---

127) 합병이라함은 M&A(Merger & Acquisition)라고도 하는데 2개 이상의 기업이 하나의 기업으로 통합되어 단일기업을 형성하는 합병(merger)과 하나의 기업이 다른 기업의 주식이나 자신의 일부 또는 전부를 취득함으로써 그 기업의 경영권을 확보하는 기업매수(acquisition)를 포괄하는 개념이다.

128) 영업의 양도라함은 일정한 영업의 목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 물적·인적 조직을 그 동일성을 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 말한다: 대판 1991. 8. 9, 91다15225.

129) 임 종률, 전게서, 479면.

당연승계설(자동승계설)[130]에 따르면 영업양도 당사자간 근로관계에 대한 합의 여부에 관계없이 종래의 근로관계는 포괄적으로 양수인에게 자동승계 된다고 본다. 그 근거로 상법에서 영업양도는 영업의 포괄적 승계이고 일부 근로자의 근로관계 승계를 배제하는 당사자간의 합의는 근기법 제30조에 따라 부당해고에 해당되어 무효가 되므로 일부 근로자의 근로관계 승계배제는 있을 수 없다고 보고 있다.

원칙승계설[131]에 따르면 영업양도의 경우 양도 당사자간 근로관계 승계에 관한 합의가 없더라도 당연히 양수인에게 승계되지만 당사자간 특약에 의해 그 일부를 배제할 수 있다고 한다. 그 근거로 영업양도에서 근로관계는 영업양도의 효과인 포괄적 권리의무의 승계에 따라 당연히 양수인에게 승계되지만 영업양도에서 영업의 동일성을 해치지 않는 범위에서 그 재산 또는 노동력의 일부를 배제할 수 있으므로 일부배제의 특약은 유효하다고 보고 있다.

대법원은 '영업양도란 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 총체, 즉 물적·인적 조직을 그 동일성을 유지하면서 일체로서 이전하는 것으로서 영업양도당사자 사이에 명시적 또는 묵시적 계약이 있어야 할 것'[132]이라고 하여 물적·인적 조직의 동일성유지를 핵심적 판단기준으로 삼고 있는 것으로 보여진다.

그리고 '영업양도당사자 사이에 반대의 특약이 없는 한 영업의 양도에 관한 합의 안에는 원칙적으로 근로관계를 포괄적으로 승계하기로 하는 내용의 합의가 있는 것으로 사실상 추정되고 근로관계의 전부 또는 일부를 제외하는 것은 지극히 예외적인 경우에 해당되므로 이러한 승계제외의 특약이 유효하기 위해서는 영업양도시 근로관계를 배제할 만한 합리적 이유가 있어야 한다'[133]고 함으로써 영업양도에 관한 합의 내에 근로관계를 포괄적으로 승계한다는 합의가 포함되어 있는 것으로 추정하고 있다. 그리고 '영업양도 당사자 사이에 근

130) 임 종률, 전게서, 480면.
131) 이 병태, 전게서, 637면; 김 형배, 전게서, 419면; 이 영희, 노동법, 법문사, 2001, 613면; 이 상윤, 노동법, 법문사, 1997, 472면; 대판 1994. 6. 28, 93다33173.
132) 대판 1997. 6. 24, 96다2644; 대판 1995. 7. 14, 94다20198; 대판 1994. 11. 8, 93다18938 등.
133) 대판 1994. 6. 28, 93다33173.

로관계의 일부를 승계의 대상에서 제외하기로 하는 특약이 있는 경우에는 그에 따라 근로관계의 승계가 이루어지지 않을 수 있으나, 그러한 특약은 실질적으로 해고나 다름이 없다 할 것이므로 근기법 제27조 제1항(현행 근기법 제30조 제1항)의 소정의 정당한 이유가 있어야 유효하다'[134]고 한다.

생각컨데 당연(자동)승계설은 영업양도시 근로자보호의 입장에서 양수인에게 근로관계의 이전을 강제하는 입장이나 그러한 강제력을 뒷받침할 수 있는 명문의 규정이 없다고 보여진다. 그리고 원칙승계설이 영업양도의 합의 속에 당사자사이에 반대의 특약이 없는 한, 원칙적으로 근로관계를 포괄적으로 승계하기로 하는 내용의 합의가 있는 것이 사실상 추정된다는 입장이나 반대의 특약이 있는 경우에 그 특약이 유효하기 위하여는 근기법 제30조 제1항의 '정당한 이유'가 있어야 하는데 이렇게 된다면 당연(자동)승계설과 구별이 없어지게 된다고 한다[135][136]. 이와 관련하여 대법원 판례는 당연승계설의 입장[137]과 원칙승계설[138]의 입장에서 견해를 밝히고 있다.

이렇게 학설과 판례가 나누어지는데 있어서는 기업변동시에 영업양도에 있어서 근로관계의 이전에 대한 명문의 규정이 없기 때문이며 이를 법정책적 구호로 추상적인 근로자보호의 이념으로서의 해석에 맡길 것이 아니라 입법을 통한 명문의 규정으로 해결하는 것이 바람직하다고 보여진다.

3. 기업변동시 취업규칙의 효력

---

134) 위의 대법원 판례 93다33173.

135) 임 종률, 전게서, 480면.

136) 이와 관련하여 김 형배 교수는 원칙승계설이 당연승계설과 구별되는 독자성을 유지하기 위하여 배제특약의 유효성의 근거를 영업양도계약을 체결하게 된 전후의 사정과 경위와 양수인의 장래의 효율적 사업계획 및 특히 양수인이 계약을 체결하게된 목적 등을 고려해서 신축적으로 해석해야 할 것이라고 한다: 김 형배, 전게서, 421면.

137) 대판 1991. 8. 9, 91다15225; 대판 1991. 3. 22, 90다6545; 대판 1997. 6. 27 96다49674; 대판 1999. 6. 11, 98다18353.

138) 대판 1994. 6. 28, 93다33173; 대판 1994. 11. 18, 93다18938; 대판 1995. 7. 14, 94다20198; 대판 1995. 7. 25, 95다7987; 대판1995. 9. 29, 94다54245; 대판 1996. 5. 31, 95다33238; 대판 1997. 6. 24, 96다2644.

1) 법규범설의 입장에서의 효력

기업의 변동과 더불어 승계 되는 기존의 취업규칙의 효력이 어떻게 되느냐가 또한 문제이다. 취업규칙을 법규범으로 이해하는 입장에서 보면 규범자체의 승계는 있을 수 없다는 전제하에 취업규칙의 자동적 효력을 인정하느냐의 여부에 따라 견해가 나누어 진다. 취업규칙의 효력에 자동적 효력을 인정하는 견해[139]에 의하면 취업규칙의 내용이 이미 근로조건의 구체적 내용으로 화체되었기 때문에, 근로관계 승계시 그 계약의 내용으로 이전되어 양수인이 이행의무를 지게 되는 것으로 판단된다. 이에 반하여 자동적 효력을 부인하는 견해[140]에 의하면 근로관계의 이전 시점에 적용을 받던 기존의 취업규칙으로부터 근로관계가 분리되어 이전하고, 이전 후에는 합병회사에 적용되던 취업규칙의 기준에 따라 적용·보충되는 것으로 이해하고 있다.

판례는 취업규칙의 법적 성질을 법규범설의 입장에서 파악하고 있으면서 기업변동시 취업규칙에 대해서는 별도의 논거를 제시함이 없이 취업규칙에 따른 근로조건의 이전을 인정하고 있다. 그리하여 '근로관계 승계 후의 퇴직금 규정이 승계 전의 퇴직금 규정보다 근로자에게 불리하다면 근기법 제95조 제1항(현행 근기법 제97조 제1항) 소정의 당해 근로자 집단의 집단적인 의사결정방법에 의한 동의 없이는 승계 후의 퇴직금 규정을 적용할 수 없다'[141]고 하거나 '합병 당시 취업규칙의 개정을···통하여 합병 후 근로자들의 근로관계 내용을 단일화하기로···하는 새로운 합의가 없는 한···퇴직금 관계에 관하여 종전과 같은 내용으로 승계하는 것'[142]이라고 하고 있다.

그러나 취업규칙을 법규범으로 본다면 사업의 양도 내지 합병시 기존의 취업규칙인 법규범이 승계대상으로 되는 것으로 보기에는 여러 관점에서 문제가 있을 수 있다고 한다.[143]

---

139) 임 종률, 전게서, 156-157면 ; 이 병태, 전게서, 209-211면.
140) 박 상필, 전게서, 477면; 김 유성, 전게서, 205면; 박 홍규, 전게서, 1009면.
141) 대판 1994. 8. 26, 93다58714; 대판 1995. 12. 26, 95다41659.
142) 대판 1994. 3. 8, 93다1589.

취업규칙의 작성·변경이 사용자의 권한에 속하는 것으로 파악한다면 이는 사용자가 취업규칙에 구속되는 것을 의미하는 것이 아니라 오직 취업규칙에 의해 규율된 근로조건에 구속되는 것을 의미하는 것이라고 한다.[144]

또한 취업규칙을 법규범으로 이해하는 한편, 계약관계의 승계와는 달리 법규범의 승계란 본질적으로 기업변동 효과에 상응하지 않는다는 점에 비추어 본다면 취업규칙 효력의 승계라는 결과는 도출되지 않으며 다만 취업규칙의 법규범설을 인정하면서도 취업규칙의 자동적 효력을 인정하는 경우에는 달리 판단 될 것이라고 한다. 그것은 법규범으로 성립된 취업규칙의 내용이 근로조건으로 화체 될 경우에는 취업규칙과는 별도로 취업규칙의 내용이 근로관계의 내용을 이루면서 존속하게 되는 것이기 때문이라는 것이다. 그리고 이러한 결과는 취업규칙 자체의 승계가 아니라 취업규칙의 내용이 다른 경로를 통해 근로관계로 화체되므로 기업변동의 효과로 취업규칙 자체가 승계 되는 것과는 달리 판단될 수 있는 것으로 결국 취업규칙의 법규범성을 인정하는 이론을 취하더라도 취업규칙 자체의 승계라고 하는 결론은 도출되지 않는다라고 한다.[145]

2) 계약설의 입장에서의 효력

취업규칙을 비록 사용자가 일방적으로 작성한다 하더라도 그 자체로서 법규범의 성질을 갖는 것이 아니라 단지 근로자에 대한 청약의 의미만을 가지고 어떤 형태로든 근로자의 동의를 통하여 구속력을 발휘한다고 보는 계약설의 입장에 의하면[146] 취업규칙의 작성 내용은 이미 근로계약의 내용으로 전환되므로 기업변동시 취업규칙의 승계여부는 곧 승계 되는 근로관계의 의미에 따

143) 김 소영·박 종희, 기업변동시 노동법적 쟁점과 정책과제, 한국노동연구원, 1999 54-55면.
144) 하 경효, 위의 논문, 180면.
145) 김 소영·박 종희, 위의 논문, 54-55면.
146) 김 형배, 전게서, 210-211면.

라 판단이 달라지게 된다. 이를 인정할 경우 승계 받는 사용자의 사업장에 이미 또 다른 취업규칙에 존재하고 있는 때에는 승계 된 근로자가 동 취업규칙의 적용을 받게 될 것 인지의 여부는 승계 근로자의 동의에 따라 결정될 것이라고 한다.[147]

다만 이 경우에도 새로이 적용될 취업규칙의 불리한 내용과 관련하여 근기법 제97조 제1항의 단서에 따라 집단적 동의의 형태가 갖추어지는 경우에만 적용을 인정할 것인가 아니면 개별 근로자의 동의로 적용을 인정할 것 인지의 문제가 남는다고 한다.[148]

이에 대한 판단은 취업규칙을 정형화된 집단적 노사계약의 형태로 간주함으로서 기업변동 이후에도 승계 된 근로자의 근로관계의 내용을 형성하는 근로계약의 형태로 계속 존속하게 되는 것으로 볼 수 있고, 이 경우 정형화된 근로계약으로서 취업규칙의 불이익한 변경시에는 적어도 집단적 의사결정방식에 의한 동의를 얻도록 하고 있는 기본 취지가 개별 근로자의 보호에 있는 만큼 집단적 동의를 불이익하게 변경할 수 있는 것으로 보는 것이 타당하다고 한다.[149]

3) 소 결

생각컨데 기업변동시 노동관계 승계의 효과는 근로계약 당사자의 변경에 불과하고 근로조건의 변경을 당연히 수반하는 것이 아니므로 양수인은 양도인으로부터 승계한 취업규칙이나 근로계약에서 정한 근로조건을 준수하여야 할 것으로 보여진다.(앞서 언급하였던 자동승계설이나 원칙승계설에 따르더라도)

그러나 취업규칙의 통일적 적용(기존의 양도인으로부터 양도받는 근로관계에서의 취업규칙과 양수인의 양도받기 전에 가지고 있던 근로관계에서의 취업규칙이 병존하게 되어 바람직하지 않기 때문에)을 위하여 취업규칙을 하나로

147) 하 경효, 위의 논문, 182면.
148) 하 경효, 위의 논문, 182면.
149) 김 소영・박 종희, 위의 논문, 56면.

통합하는 경우에 있어서 그것이 양도되는 근로자에게 불이익하게 변경되는 경우에는 근기법 제97조 제1항의 단서에 의하여 동의를 받아야 할 것으로 보여진다.[150]

그리고 법규범설이나 계약설은 앞서 언급[151]하였던 바와 같이 취업규칙의 구속력의 근거와 구체적인 시행상의 문제에 있어서 견해의 차이가 있는 것으로 보여지며 취업규칙이 노사관계당사자들을 구속한다는 점에서는 계약설이나 법규범설의 차이는 없다고 고찰된다.

4. 기업의 변동으로 인한 취업규칙의 변경의 구체적 사례

IMF에 긴급구제금융 신청과 더불어 우리 나라는 1997년 경제위기를 맞이하였고 그 여파로 1999년까지 많은 기업들의 변동이 있었다. 금융산업의 구조조정으로 5개 은행이 퇴출되었고 제2금융권의 상호간의 합병, 현대자동차 및 기아자동차가 각각 관련사업부분을 흡수・합병하였으며, 철도차량・우주항공산업・반도체 부분 등에서 각각 합병 또는 일련의 분할합병 등이 이루어졌다.

1) 하나은행

1998년 6월 29일 하나은행은 충청은행을 P&A[152]방식으로 강제 인수하였고, 1999년 1월 1일 보람은행과 합병하였다. 이에 따라 피 인수은행의 근로자들의 근로관계가 인수은행에 승계되는지에 대한 노동법적 문제점이 발생되었는바 살펴보면 다음과 같다.

첫째 근로관계의 이전문제에 관하여 회사합병의 경우에 합병되는 회사의 모

150) 대판 1995. 12. 26, 95다41659; 대판 1997. 12. 26, 97다17575.
151) 위 논문 제2장 제2절 4.
152) P&A(Purchases and Assumptions)란 미국에서 통용하던 금융기관의 퇴출방식의 한 형태로서 공개입찰을 통해 선정된 인수은행이 도산은행의 모든 예금채무 및 일부 비예금채무를 인수하고 자산의 전부 또는 일부를 취득하는 것을 말한다.

든 권리·의무가 그대로 존속회사 또는 신설회사에 법률상 당연히 포괄승계[153] 되므로 합병의 효과로서 근로자들의 근로관계가 존속회사인 하나은행에 포괄적으로 승계 되는 것은 당연한 귀결이다.

둘째 단체협약의 적용문제로서 합병 후 하나은행에는 구 하나은행의 단체협약과 구 보람은행의 단체협약이 병존하고 있다. 이는 일반적으로 근로자를 그대로 승계 하는 영업양도의 경우에 있어서 특별한 사정이 없는 한 종전의 단체협약도 잠정적으로 승계 되어 존속하는 것으로 보아야 한다라는 판례[154]의 태도와 그 취지를 같이 하는 것으로 보여진다.

셋째 취업규칙의 적용문제로서 피 합병회사에서 취업규칙의 적용을 받던 근로자들의 근로관계가 합병회사에게 승계 된 경우에 취업규칙에 의하여 정하여진 근로조건은 근로관계의 내용으로서 합병회사에 그대로 승계 된다.

판례[155] 또한 별다른 근거를 제시하고 있지 않지만 취업규칙에 따른 근로조건의 이전을 인정하고 있다. 이와 관련하여 근로조건 중에 우선 직급 및 급여규정과 관련하여 구 하나은행, 구 보람은행 출신별로 별도로 종전 수준(1998년 기준)을 그대로 유지하고 있으며 다음으로 퇴직금 규정은 구 하나은행노동조합과 구 보람은행노동조합이 각각 존속회사인 하나은행과의 합의를 통하여 (상기의 두 노동조합은 근로자의 과반수를 대표하는 노조에 해당한다) 퇴직금 누진제 규정을 폐지하고 퇴직금 단수지급 규정으로 개정하여 취업규칙의 불이익 변경의 효력과 관련하여서는 아무런 문제가 없다고 판단된다.

2) 국민은행

국민은행은 1998년 9월 11일 장기신용은행과 합병하기로 발표하고 양해각서를 교환하였다. 이에 합병에 의한 노동법적 문제점을 살펴보면 우선 노동조합의 승계와 단체협약의 적용의 문제로 합병당시 구 장기신용은행노조는 스스로

153) 상법 제235조, 제530조 제2항, 제603조.
154) 대판 1989. 5. 23, 88누4508.
155) 대판 1997. 12. 26, 97다17575.

이미 해산을 결정하고 1999년 1월 4일 행정관청에 해산절차를 밟음으로서 소멸하였고 그 효과로서 구 장기신용은행노조와 사용자간에 체결한 단체협약은 당연히 소멸하였으며 구 장기신용은행에 존재했던 단체협약의 국민은행에의 이전 문제는 발생하지 않았다.

따라서 현재 국민은행에는 하나의 노조만이 존재하고 있으며 단체협약은 구 국민은행노조가 체결한 단체협약만이 존재하고 있을 뿐이다. 둘째 취업규칙의 적용문제로서 국민은행과 장기신용은행의 합병 시 대두된 가장 큰 문제점이자 합병 후 노사대립의 쟁점이었던 '직급 및 직위규정'은 구 국민은행과 장기신용은행의 중간에 해당하는 제3의 기준으로 변경하였다. 상대적으로 높은 수준에 있었던 장기신용은행 근로자들의 직급과 직위는 하향조정하고 구 국민은행 근로자들의 직급과 직위는 상향조정하였던 것이다.[156]

구체적인 예를 살펴보면, 승진연한과 관련하여 구 국민은행의 5급 직원이 4급으로 승진하는데 평균적으로 소용되는 기간을 종래의 5년에서 3년으로, 4급 대리에서 4급 과장으로 승진하는 연한은 종래 4년에서 3년으로 단축하였다. 한편 장기신용은행의 근로자들은 직급과 직위를 분리하여 직급은 유지하고 직위는 일부 하향 조정하였는데 예를 들면 차장을 과장으로 하향 조정하였다.

노동법적 관점에서 문제되는 것이 바로 상기의 장기신용은행 출신 근로자들의 직위의 하향 조정이라 할 수 있다. 이것은 취업규칙상의 근로조건의 불이익 변경에 해당하므로 장기신용은행 근로자들의 동의를 얻어야 유효한데, 동의 여부에 대한 사실관계는 확인된 바 없다.

다음으로 퇴직금지급 규정과 관련하여 보면 존속회사인 국민은행과 근로자들 사이의 합의하에 구 국민은행과 장기신용은행의 중간수준 정도의 퇴직금누진제 규정을 마련하였으며 합병기일 바로 전에 장기신용은행의 근로자 전원이 퇴직금을 중간 정산하여 지급 받았다. 따라서 이들의 경우는 취업규칙의 불이익변경에 관한 법적 문제가 발생하며 그 유효성이 검토되어야 할 것으로 보여

156) 구 국민은행과 장기신용은행 사이의 근로조건의 차이에 관하여는 김 소영·박 종희, 위의 논문, 118-119면.

진다.

제4장 취업규칙의 변경에 따른 문제점의 개선방향

제1절 '합리성'이론의 배제

1. 일본에서의 '합리성'이론의 필요성

앞서 상술한바와 같이 취업규칙의 불이익 변경에 관하여 일본 노동기준법 제90조에서 취업규칙의 작성 또는 변경에 대하여 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 의견을 듣도록만 규정되어 있어, 취업규칙 불이익변경의 경우에 우리 나라와 같은 근로자집단의 동의를 얻도록 하는 규정을 두고 있지 않다.

따라서 일본에서는 불이익 변경된 취업규칙의 구속력에 대해서는 전적으로 판례법리에 의해 규제되고 있는 것이다. 그리하여 최초의 취업규칙의 불이익 변경에 관한 판결로 秋北버스사건, 최고재판소 1968, 12, 25 이 있었는바 이후 일본의 최고재판소는 취업규칙의 불이익변경의 구속력을 변경의 합리성 유무에 의해 판단하는 구조를 확정시키고 그 판단기준을 분명히 하였다. 즉, 취업규칙 불이익변경의 구속력에 대한 일본에서의 판례는 당해 변경의 내용과 변경의 필요성과의 비교형량을 기본으로 하면서, 불이익의 정도·내용 등을 참작하여 변경과 관련된 근로조건 개선의 유무·내용을 충분히 고려하면서 동시에 변경의 사회적 상당성과 노동조합과의 교섭과정, 기타 종업원의 태도 등도 감안하는 것으로 말할 수 있다.[157]

---

157) 菅野和夫, 전게서, 105-106면.

생각컨대 일본의 경우에는 우리 나라와 같은 근기법 제97조 1항의 단서조항이 없기 때문에 취업규칙의 불이익변경의 여부는 오로지 판례에 의하여 확립된 '합리성'이론에 의하여 해결 할 수밖에 없을 것으로 보여진다.

2. 우리 나라에서의 '합리성'이론의 배제

근기법 제97조 1항의 단서에 의하여 취업규칙의 불이익변경에 관하여 근로자집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 있어야 함은 앞서 살펴보았다. 그리고 동 조항이 강행규정이므로 오직 취업규칙의 불이익변경에 관하여는 상기의 동의만을 요한다 할 것이다. 그럼에도 불구하고 최근까지도 '합리성'이론에 의하여 취업규칙의 불이익변경을 해결하려고 하고 있다.[158]

지금까지의 대법원 판례에서는 사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등 관련된 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다라고 하고 있다.

한편 '합리성'이론이 정부의 정책에 의하여 남용될 수 있다는 점에 문제가 있다. 그것은 1980년대 초에 정부의 방침에 따라 정부관련기관에서 행해진 퇴직금규정의 일방적인 하향조정이 있었고, 최근의 IMF이후에 어려운 경제여건을 들어서 대규모의 부당해고 및 근로조건의 하향을 단행하였던 사실들이 이

158) 대판 2002. 6. 11, 2001다16722에서는 사용자가 일방적으로 새로운 취업규칙의 작성·변경을 통하여 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이나, 당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 하여 '합리성'이론으로 상기의 사건을 해결하고 있다.

를 뒷받침해 준다. 그리고 '합리성'이론이 법관의 자의에 의하여 판단되어질 경우에 있어서 근로자의 생존권적 측면에서 큰 손실을 입을 수 있다는 점을 감안한다면 우리 나라에서의 '합리성'이론은 배제되어야 한다고 보여진다.

더군다나 우리의 근기법에서는 제97조 제1항의 단서에서 분명히 취업규칙의 불이익 변경시에 근로자집단의 동의가 있어야 함을 규정하고 있으므로 이 규정의 강행성을 실현시키기 위하여서도 타당성 없는 '합리성'이론은 배제되어야 할 것이다.

다만 초법적인 경우에, 예컨데 경제적 환란·기업의 도산위기 등의 절대절명의 긴박한 위기상황에서의 취업규칙의 변경에 대한 '합리성'이론의 적용은 그 적용에 있어서 타당성이 존재한다고 보여진다.

제2절 불이익 변경시 효력상의 문제점의 개선방향

취업규칙의 불이익 변경시의 효력에 관한 문제점은 앞서 살펴본 바와 같으며, 이러한 일련의 문제점의 대부분은 취업규칙의 불이익 변경이 사후 단체협약의 협약에 의하여 효력이 인정됨에 있어서 나타난다. 이에 취업규칙과 단체협약의 관계에 대한 정립이 필요할 것으로 보여지며, 아울러 취업규칙과 단체협약에서의 유리의 원칙의 타당성범위에 대한 고찰이 이루어져야 할 것으로 생각된다.

1. 취업규칙과 단체협약의 관계의 정립

취업조건, 복무규율, 근로조건 등에 대하여 획일적인 처리를 하기 위하여 사용자가 작성하는 취업규칙은 당해 사업·사업장의 전체 종업원을 대상으로 한 것이나 종업원이 노동조합에 가입하고 그 조합과 사용자간에 체결된 단체협약의 적용을 받는 경우, 단체협약과 취업규칙이 동일사항에 대하여 달리 정하고

있으면 단체협약이 취업규칙에 우선하여 적용된다. 근로관계의 규율은 노사가 대등한 입장에서 단체교섭을 행한 결과로서 얻어지는 집단적 합의에 의할 것이 기대되고 있고, 근로자측의 의견청취가 이루어져도 결국은 사용자가 일방적으로 작성·변경하는 취업규칙에서는 노·사의 대등성이 보장되지 않고 진정한 의미에서의 근로자의 보호를 여기에서 기대하는 것은 곤란하기 때문이다. 이 점에서 근기법 제99조 제1항은 '취업규칙은 법령 또는 당해 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없다'고 규정하여 근대적 노사관계법의 원칙을 확인하고 있다.

그런데 이와 같이 취업규칙과 단체협약의 관계는 이미 근기법상 정하여져 있지만 지금까지 살펴본 사항(불이익변경의 효력·판단기준 등)에서 취업규칙에 대한 불이익 변경시에 그 동의로서 단체협약에 의하는 경우(앞서 언급하였던 동의의 방식에서 부서별·기구별 의견취합방식 및 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 상호간에 의견을 교환하여 찬반의견을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식이외의 사후 단체협약을 통해서 하는 경우) 이에 대한 효력을 무조건 인정한다는 것은 아니 된다 할 것이다.

근래 퇴직금지급률에 관한 취업규칙 불이익변경이 요건을 거치지 아니하고 행해져 무효인데 후에 단체협약으로 이를 소급적으로 동의하는 것을 유효하다고 보는 판례가 다수 등장[159]하고 있는데, 이는 근로자의 기득권보호와 신뢰보호의 원칙 등에 비추어 보아도 타당치 못하다고 한다.[160][161]

---

159) 대판 1992. 7. 24, 91다34073; 대판 1992. 11. 24, 91다31753; 대판 1994. 5. 24, 93다46841; 대판 1997. 8. 22, 96다6967 등.

160) 독일에서의 사업장협정 규정의 한계에 대해 논하고 있는 바를 살펴보면(BAG, *AP* Nr 26 zu §611 BGB Fursorgepflicht uber die Unzulassigkeit eines Haftungsausschusses fur den Werkparkplatz) 근로관계의 존립에 관한 정함과 이행기에 있는 개개의 청구권은 불이익변경될 수 없다고 하며, 단체협약만큼 자율적이라고 볼 수 없는 사업장협정에 대해 법원의 정당성에 의한 통제가 행해지고 있다.

161) 일본 최고재판소 제1소법정판결, 1989. 9. 7 노동판례 546호에서 이미 발생한 구체적 권리로서의 퇴직금청구권을 사후에 체결된 단체협약의 소급적용에 의하여 처분, 변경함은 허락되지 않는다고 밝히고 있다.

그리고 이와 같은 불이익 변경이 단체협약에 의한 소급적 동의에 있어서 특히 문제점으로 인식되어온 것이 퇴직금에 관련된 사항이다. 퇴직금이 근로자의 퇴직 후 생활설계의 기본이 된다는 중요성에 비추어 일본의 경우에 있어서는 취업규칙상 퇴직금규정의 불이익변경에 대하여 극히 엄격한 해석[162]을 하고 있는 것으로 보인다. 예컨대 大阪日 日新聞社事件[163]에서는 앞의 秋北ハス 사건 最高裁判決을 인용하면서 '사용자가 퇴직금에 관한 취업규칙을 변경하여 종래의 기준보다 낮은 기준을 정하고 그 효력이 전체근로자에게 미치게 한다면 기왕의 근로의 대상인 임금에 관하여 사용자의 일방적인 감액을 긍정하는 것과 같은 결과를 초래하는 것이고, 이와 같은 취업규칙의 변경은 가령 사용자에게 경영부진 등의 사정이 있다해도・・・도저히 합리적인 것이라고는 볼 수 없으므로 위 취업규칙 변경은 적어도 변경 전부터 고용되어 있던 근로자에 대해서는 그 동의가 없는 이상 변경의 효력이 미치지 아니한다고 해석함이 상당하다'라고 하고 있다.

이와 같이 일본에서는 취업규칙의 불이익변경과 관련하여 '합리성'이론에 의하여 해결하고 있음은 앞서 언급한바와 같고, 아울러 퇴직금 규정의 불이익변경에 대하여 합리성이 있다고 인정한 것은 大曲農協事件 제1심[164] 및 그 最高裁判決[165], 그리고 空港環境整備協事件[166]을 제외하면 거의 보이지 아니한다.

위의 大曲農協事件에서도 '합리성'이론을 적용하면서 불이익변경의 경우에 '원고가 변경된 것에 대하여 받아들이지 않을 수 없는 고도의 필요성에 근거한 합리적인 내용의 것'을 요하고 있다.

이와 같은 일본의 판례들을 본다면 퇴직금 규정의 불이익변경에 있어서 기득권 및 근로자들의 신뢰이익의 침해를 방지하기 위한 경과조치가 마련되어

---

162) 이러한 일본의 취업규칙상 퇴직금의 불이익 변경의 사례에 관하여 더 자세한 것은 西村健一郎, 環境變化と勞働條件の變更をぬくる判例法理, 季刊 勞働法 제172호, 42-43면 참조.

163) 大阪高判, 1979. 5. 28 판시, 612호 93면.

164) 秋田地大曲支判, 1982. 8. 31 勞判 450호, 76면.

165) 最3小判, 1988. 2. 16, 勞判 512호 7면.

166) 東京地判, 1994. 3. 31, 勞經速報 1528, 3면.

있다고 보여진다.

다만 이에 관하여 일본의 경우에는 우리의 근기법 제97조 제1항의 단서규정이 없으므로 '합리성'이론에 의하는 것은 필연이라 할 수 있겠으나, 우리의 경우에는 이러한 '합리성'이론이 배제되어야 함은 앞서 언급하였다.

생각컨데 단체협약에 의한 취업규칙의 불이익 변경의 효력은 인정된다고 보여지며, 다만 그 협약에 의하여 근로자들의 기득 이익 및 신뢰이익이 침해받는 경우에 있어서 협약 내용의 전체적인 사항을 구체적으로 판단하여야 할 것으로 보여진다.

그것은 일반적으로 근로자들은 통상 보다 나은 근로조건의 획득을 예정하면서 노동조합을 결성하고 다수의 힘을 배경으로 하여 법률상 사용자와 대등한 지위에서의 교섭을 행하려고 노력할 것이고, 여기서 유리한 협상을 이끌어 내면 일반적으로 근로조건의 향상을 기대할 수 있기 때문이며 노동조합에서는 사용자와의 단체교섭시에 전체적으로 불이익한 변경에 대한 협약체결은 하지 않을 것으로 보여지기 때문이다.

2. 유리한 원칙의 타당범위에 대한 고찰

독일에서의 단체협약법과는 달리 우리의 노조법은 유리의 원칙에 대하여 전혀 규정된 바가 없다. 이러한 이유로 인하여 유리의 원칙의 인정여부 및 타당성 범위에 대한 논쟁이 끊이질 않는 것이다. 유리의 원칙의 인정여부에 대한 학설은 이미 앞서 살펴보았으므로 다음에서는 유리한 원칙의 타당범위에 대하여 독일의 경우와 비교하여 고찰하기로 한다.

독일에 있어서도 유리의 원칙은 실제로 중요한 의의를 지니는데 그것은 근로조건의 통일적인 규율을 요구하는 질서형성원리와 유리원칙을 어떻게 조정하는가에 있다고 한다.[167] 우선 종전의 유리한 근로조건이 개별계약상 약정된

167) 김 재훈, 위의 논문, 42면.

것인 경우 통설은 불리한 기준을 정한 새로운 협약의 성립에 불구하고 종전의 유리한 근로조건이 타당하다는 점을 인정한다.[168]

다만, 근로계약에서 이미 규정되어 있는 근로조건을 단체협약에 의해 인하하는 경우까지도 유리의 원칙이 적용되는지 하는 문제에 대하여 단체협약의 근로조건 통일화기능을 중시하여 기존의 유리한 근로조건을 단체협약으로 인하하는 경우에는 유리원칙이 적용되지 아니한다는 견해도 있다.[169] 그러나 오늘날 독일에서는 이와 같은 견해를 지지하는 입장은 거의 존재하지 아니한다.[170]

다음으로 종전의 유리한 근로조건이 협약에 근거한 경우에는 즉, 우리 나라의 경우처럼 동의의 방식으로 여타의 방법이 아닌 단체협약을 통한 변경으로 유리하게 된 경우에는 동일한 사안에 대한 차후의 단체협약으로 불이익 변경하는 것을 인정하고 있다.[171]

상술한 독일의 경우를 살펴보건데, 기본적으로 질서형성원리에 의하여 단체협약에 의한 취업규칙의 불이익 변경은 인정되는 것으로 하고, 근로자의 개인인격의 발전의 자유를 보장함과 동시에 근로자 개인의 의사를 존중하는 것으로 개별적 근로계약의 경우에는 단체협약에 의한 근로조건의 불이익변경은 유리의 원칙이 적용되는 것으로 보여진다.

현행 우리의 노조법은 독일의 경우와 달리 단체협약의 규범적 효력을 규정하면서 유리의 원칙의 인정 여부에 대하여는 정함을 두지 않고 있다.(독일의 경우 단체협약법 제4조 제3항에서 유리의 원칙을 인정하고 있다) 그리고 동의의 방식에 대한 구체적인 규정도 없는 것으로 보여진다.

---

168) Hueck-Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitrechts*, Bd Ⅱ/1, 7Aufl Verlag Franz Vahlen G m b H, 1966, 536면.

169) Schmidt, Einfluβ eines Tarifvertragsgesetz, Auf Bestehende Gunstrigere Abmachung, *RdA*, 336면.

170) Wlotzke, *Das Gunstigkeitsprinzip im Verhaltnis des Tarifvertages zum Einzelarbeitsvertrag und zur Betriebsverinbarung*, 1957, 45면: BAG, Urt v 27 11 1958, *AP* Nr 26 zu §1 TVG Tarifvertrage Rundfunk.

171) Hueck-Nipperdey, 전게서, 586면; Schaub, *Arbeitsrechts-Handbuch*, 5 Auf, 1983, 1200면.

생각컨대 단체협약은 근로자보호를 위한 근로조건의 최저기준을 정한 것임으로 취업규칙에 의하여 단체협약보다 유리한 근로조건으로 합의한 것은 유효하다 할 것이고, 유리하게 변경된 근로조건을 사후에 단체협약을 통하여 불리하게 변경하는 것은 문제가 있다고 보여진다.[172][173] 즉, 독일에서의 경우처럼 단체협약에 의한 취업규칙의 변경(유리한 변경이든, 불리한 변경이든 관계없이)은 질서형성원리를 적용하여 인정된다고 봄이 타당할 것으로 보여지지만, 근로자 보호의 차원에서 종전의 유리한 근로조건이 단체협약이 아닌 여타의 동의방법에 의하여 이루어진 경우(일반적으로 근로조건에 관한 모든 부분은 단체협약을 통하여 체결되지만, 앞서 언급한 동의 방식에는 다수의 방법이 존재한다는 점을 주지하고)에는 차후 단체협약을 통하여 동일한 내용의 것을 불이익 변경해서는 아니 될 것으로 보여지며, 이를 불이익 변경하려고 한다면 종전의 방식으로 인한 근로자집단의 동의를 얻어야 할 것으로 보여진다.

또한 단체협약의 당사자인 노동조합은 개인근로자와는 달리 사용자에 대하여 교섭상의 대등한 지위를 보유하고 있으므로 진정한 의미의 자치적 기초 위에서 이루어진 단체협약의 규정은 그것이 유리한 것이건 불리한 것이건 근로계약의 경우와는 달리 그대로 규범적 효력을 가져야 할 것[174][175]이지만, 현실적으로 다음과 같이 판단하여야 할 것으로 보여진다.

---

172) 이와 관련하여 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준을 정한 단체협약상의 규정이 근로자에게 불리한 경우에 그러한 규정이 규범적 효력을 가질 수 있는가에 대한 논의에 있어서 우리 나라와 일본의 학계에서는 부정하는 견해가 일반적이다라고 김 형배 교수는 언급하고 있다: 김 형배, 전게서, 630면.

173) 유리원칙은 단체협약이 규율하는 근로조건 보다 유리하게 변경된 근로계약상의 근로조건을 보호하기 위하여 기능 하는 점에서 이설이 없으며, 독일의 단체협약법 제4조 제3항의 '다른 약정이 근로자의 이익을 위하여 행하는 규정의 변경을 포함하는 경우' 라고 하는 문구도 이와 같은 상황을 염두에 둔 것이라고 할 수 있을 것이다 : Wiedemann/Stumpf, *Tarifvertragesgesetz*, 5 Auf 1977, §4 Rn 226 참조.

174) 독일에 있어서는 기본적으로 이와 같은 이론적 견해가 지배적이다.

175) 이와 관련하여 김 재훈, 위의 논문, 145-148면: 이 논문에서 독일의 경우 사업장자치의 한계를 언급하면서 일반적인 근로계약은 후속 되는 사업장협정 또는 단체협약에의하여 파기될 수 있다고 하며, 유리원칙 대신에 질서원칙(서열이 높은 규정은 서열이 낮은 규정에 우선한다는 원칙)이 적용된다고 한다.

첫째 단체협약상의 규정이 근로자에게 유리할 것인가 불리할 것인가 하는 것은 종합적으로 평가해야 할 것이다.

둘째 노동조합은 경제의 불황 또는 회사의 경영난을 고려하여 일시적으로 불리한 협정을 할 수도 있을 것이나 이는 단기적 시각으로 볼 때는 불이익하더라도 장기적인 시각으로 볼 때, 노동조합이 자주적으로 협정한 경우에는 그 규정은 효력을 가진다고 해석하여야 할 것이다.

셋째 아무리 노동조합이 자주적으로 결정한 것이라 하더라도 그것이 근기법의 기준에 위반하거나 신의칙에 위반되는 경우에는 무효라고 해석해야 할 것이다.

제5장 결 론

취업규칙제도는 근대기업에서 노동력 관리상의 편의를 위하여 사용자에 의해 일방적으로 작성된다. 연혁적인 측면에서 보면 그 내용도 복무규율이라든가 이의 위반에 대한 제재를 주로 담고 있는 것이어서 본래 사용자의 편의를 위한 제도임을 부정할 수 없을 것이다. 그러나 노동력이 대량적·획일적으로 거래되고 있는 오늘날의 상황에서 취업규칙을 사용자의 일방적 작성에 맡기는 것은 불합리하다고 본다. 그러므로 노·사 대등을 바탕으로 근로자가 보다 적극적으로 참가하는 논리를 포함하는 방향으로 취업규칙법제가 재구성될 필요가 있으며 근로조건에 관한 기준이 되는 모든 사항은 실질적으로 노·사가 대등한 지위에서 공동으로 결정해 가는 방안을 모색해야 할 것으로 보여진다.

또한 산업혁명 이후 기업경영의 현실적 필요에서 등장한 취업규칙이라는 제도의 법적 성격 및 근로자에 대한 구속력을 중심으로 하는 그 효력의 문제는 자유로운 인격체 사이의 법률관계가 계약을 원칙으로 한다는 근대 사법적 원칙에서 보면 여러 논의를 불러일으키게 된다. 하지만, 현행 노동관계법의 목적은 근로자 자유로운 인격체의 보호와 생존권 및 여타의 기본권 보장에 있으므로 근대 사법의 원칙이 모두 적용된다고 보기에는 무리가 있다고 생각된다. 이에 취업규칙의 법적 성질에 관하여는 법이 근로자의 보호와 노사관계의 안정을 위하여 특별히 근로계약을 직접 규율하는 법적 효력을 부여하였다고 이해하는 법규범설이 타당하다고 보여지며, 이것은 단체협약의 규범적 효력을 법규범설로 파악하는 것과 통한다고 할 수 있겠다.

그리고 취업규칙의 변경에 관한 문제점에 관하여 앞서 살펴본 바와 같이 많은 문제점이 지적되고 있는바, 이에 대한 개선방향으로는 다음과 같은 논의가 이루어져야 할 것으로 고찰된다.

첫째 취업규칙의 불이익변경은 대법원에서 제시하고 있는 '합리성'이론을 배제하고 오직 근로자들의 집단적 동의로만 하여야 한다는 근기법 제97조 제1항의 단서규정에 의하여 이루어져야 할 것이다.

둘째 취업규칙과 단체협약의 관계에서 취업규칙이 불이익하게 변경되어 동의를 얻지 못한 상태로 있다가 사후에 단체협약을 통해서 취업규칙을 불이익하게 변경하는 경우(이른바 단체협약에 의한 취업규칙의 소급효 문제)에는 그 변경의 효력이 무조건 인정되어서는 아니 될 것으로 보여진다. 그것은 단체협약을 통해 취업규칙이 불이익변경 된 경우 그 효력을 무효로 하자는 것이 아니라, 취업규칙의 불이익변경의 시점과 단체협약을 통해 변경된 시점이 다름에도 불구하고 근로자 집단의 집단적 동의를 받지 못하여 불이익변경된 취업규칙의 근로조건을 소급하여 취업규칙이 불이익변경된 시점으로 거슬러 올라가서 그 때부터 변경된 것으로 효력을 지니는 것은 문제가 있기 때문이다. 그러므로 이러한 경우에 있어서 단체협약에 의한 취업규칙의 변경은 그 효력시점을 단체협약체결이후로 하고, 체결 이전의 취업규칙이 불이익 변경되어 시행된 경우 사용자는 근로자에게 이에 대한 피해의 보상을 하여야 하며, 위 취업규칙을 지키지 않아 해고된 근로자에 대한 구제를 해야 할 것이다.

셋째 현행 우리 노동법에는 유리의 원칙에 대한 명문의 규정이 없기 때문에 근로자들의 근로조건의 변화에 대하여 기존의 취업규칙이나 근로계약이 변경된 취업규칙보다 유리한 경우에 있어서 유리의 원칙 적용여부가 오직 학설에 의하여 법정책적인 측면에서 다루어지고 있다. 이것은 근로자보호의 이념으로서 노동법전반에 걸친 목적에 비추어 유리의 원칙에 대한 입법의 불비는 아쉬움으로 남는다. 소수근로자와 비노조원들이 다수의 근로자와 노조원들의 산술적 힘에 희생될 수도 있다는 점을 간과하여서는 아니 될 것이다. 따라서 취업규칙의 불이익 변경시 상대적으로 불평등한 근로자들을 보호하기 위하여 유리의 원칙에 대한 입법이 이루어져야 할 것으로 보여진다.

넷째 기업변동시에 취업규칙의 승계(근로조건의 승계)에 관하여 살펴본 바와 같이 학설과 판례가 나누어지고 있으나 그것은 명문의 규정이 없기 때문에

취업규칙의 승계에 대한 해석론의 차이일 뿐, 양자 모두 그 근거가 근로자보호의 이념으로부터 출발하고 있다고 보여진다. 이에 기업의 변동시에 특히 영업양도에 있어서 취업규칙의 승계에 대한 입법이 이루어져야 할 것이다.

이상과 같이 취업규칙의 변경에 따른 문제점들을 살펴보고 개선방향을 미력하나마 제시해 보았다. 취업규칙의 변경에 따른 문제점은 그 동안 법정책적 관점에서만 다루어져 노동관계법률과 판례의 해석에만 의존한 경향이 많았다고 보여진다. 그러므로 앞서 언급한 문제점들에 대한 입법을 강구해야 할 것으로 보여지며 이러한 입법을 통하여 실질적인 근로자보호가 이루어져야 할 것으로 보여진다.

참고문헌

1. 국내문헌

1) 단행본

곽윤직, 민법총칙, 박영사, 2002

곽윤직, 채권총칙, 박영사, 2002

권영성, 헌법학원론, 법문사, 2003

김성환・이상덕・김정한, 취업규칙분석, 한국노동연구원, 1993

김수복, 노동법, 중앙경제사, 1991

김유성, 노동법 Ⅱ-집단적 노동관계법-, 법문사, 1997

김유성・이홍재, 노동법(Ⅰ), 한국방송대학출판부, 1993

김치선・김유성, 판례교재 노동법, 법문사, 1987

김형배, 노동법 13판, 박영사, 2002

김형배, 근로기준법, 박영사, 박영사, 1998

박상필, 한국노동법, 대왕사, 1991

박홍규, 노동법론, 삼영사, 1996

심태식, 노동법개론, 법문사, 1989

이병태, 최신 노동법, 중앙경제사, 2002

이영희, 근로계약론, 인하대학교 출판부, 1988

임종률, 노동법 3판, 박영사, 2002

하경효・박종희, 기업의 구조조정과 노동법적 과제, 한국노동연구원, 1998

한국노동연구원, ILO기본협약집, 1993

2) 논 문

고태관, 취업규칙의 불이익변경, 서울대학교 법학석사학위논문, 1994

김남준, 정년규정 신설이 취업규칙의 불이익변경에 해당하는지 여부와 노동조합장의 효력, 1997년 노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회 편저, 1998

김소영, 연봉제 실시에 관한 법적 검토, 연봉제 어떻게 할 것인가, 한국노동연구원・한국경제신문사, 1998. 3

김소영・박종희, 기업변동시 노동법적 쟁점과 정책과제, 한국노동연구원, 1999

김선수, 취업규칙의 불이익변경과 노사협의회의 동의, 월간 노동법률, 중앙경제사, 1994. 9

김 영, 취업규칙의 법리와 문제점, 노사관계 제1권 제2호, 한국노사발전연구원, 1990

김재구, 취업규칙의 변경, 대법원판례해설, 1990년 하반기(제14호), 법원행정처

김재훈, 근로조건 변경의 법리(불이익 변경의 한계를 중심으로), 서울대학교 박사학위논문, 1999

박 훈, 기업변동에 따른 제반의 근로관계에 대하여, 노동과 법, 금속산업연맹 법률원, 2001

박종희, 유리한 조건 우선의 원칙에 대한 법이론적 검토와 체계상 재구성 시론, 노동법학 8호, 한국노동법학회, 1998. 12

박종희, 현행 노동관계법상 근로자대표의 중첩성과 이에 대한 기능조정을 위한 방안, 한국노동연구원, 1998. 5

오문완, 임금형태의 변화와 법적 문제, 산업관계연구 6권, 한국노사관계학회, 1996. 6

이은영, 취업규칙의 불이익변경, 김치선박사 화갑기념논문집(노동법의 제문제), 박영사, 1983

이철수, 취업규칙에 대한 판례법리와 문제점, 사법행정, 1993. 8

임종률, 취업규칙의 법적 성질과 효력, 김학수박사 화갑기념논문집, 정진문화사, 1985
곽동준, 취업규칙의 불이익변경에 관한 연구(기업변동을 중심으로), 고려대학교 법학석사학위논문, 2002
조득주, 취업규칙의 작성・변경시 의견청취・동의의 주체에 관한 연구, 고려대학교 법학석사학위논문, 2000
하경효, 기업의 구조조정과 단체협약・노사협정 및 취업규칙의 효력, 기업의 구조조정과 노동법적 과제에 관한 토론회, 한국노동연구원, 1998. 10

2. 일본문헌

菅野和夫, 勞働法, 弘文堂, 1995
古西信夫, 就業規則論の展望, 勞働基準法の課題と展望, 青木宗也先生還歷記念論文集, 日本評論社, 1984
渡邊章, 協約自治と個別勞働者の法的地位, 日本勞働法學會誌, 제38호, 1971
本多淳亮, 勞働契約・就業規則論, 東京 一粒社, 1981
三宅正男, 就業規則, 法律學體系, 法學理論編, 1952
西村健一郎, 環境變化と勞働條件の變更をぬくる判例法理, 季刊 勞働法 제172호
石井照久, 勞働法總論, 1957
石井照久, 勞働法 總論, 有斐閣, 1979
松岡三郎, 條解 勞働基準法(하), 1959
手塚和彰, 就業規則の社會的規範としての實態と法的考察, 勞働法の解釋理論, 有斐閣, 1976,
手塚勝利, 集團的勞使關係秩序と就業規則・勞動協約の變更法理, 季刊勞働法, 제150호, 1989
吾妻光俊, 勞動契約の就業規則, 法律時報 2권 1호, 1972
有泉享, 勞働基準法, 東京 有斐閣, 1963

川崎武夫, 就業規則の效力, 現代勞働法講座 10권, 總合勞働研究所, 1986
土田道夫, 能力主義 賃金と勞働契約, 季刊勞働法 제185호, 1998
下井隆史, 就業規則一その法的性質と效力, 恒藤域二編 論爭勞働法, 總合勞働研究所, 1986

3. 독일문헌

Bulla, Das Prinzip der Sozialadaquanz im Arbeitsrcht, *RdA* 1962
Hilger, *Das betrieblich Ruhegeld,* 1959
Hueck-Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitrechts*, Bd Ⅱ/1, 7Aufl Verlag Franz Vahlen G m b H, 1966
H Wiedemann, *Tarifvertragsgesetz*, 5 Auf, 1977
Motive, Reichstagbericht von 1890, Motive Drucksachen, Nr 4 Anl Bd l
MünchHandbArbR/Richardi, Bd. 1, 1992
Nikisch, *Arbeitsrechts*, Bd. I, 3. Arbeitsrecht, 1961
P Oertmann, rechthche, Natur der Arbeitsordnung, in der Festgabe fur Hubler, 1905
R Richardi, *Kollektivgewalt und Indwtdualwille bei der Gestaltung des Arbeitsverhaltrusses,* 1968
Schaub, *Arbeitsrechts-Handbuch*, 5 Auf, 1983
Wlotzke, *Das Gunstigkeitsprinzip im Verhaltnis des Tarifvertages zum Einzelarbeitsvertrag und zur Betriebsverinbarung*, 1957
Zöllner/Loritz, *Arbeitsrechts*, 5. Arbeitsrecht, 1998